

법의 기초이론

법이란 무엇인가

당위규범: 사회구성원들이 마땅히 해야 할 것을 정하는 당위의 법칙(~해야 한다)

사회규범: 사회생활에서 발생하는 대립·분쟁을 규율하고 반사회적인 행위를 제재하여 사회적 결합을 확보하기 위한 규범

강제규범: 국가권력에 의하여 그 준수가 강제되는 규범. 법의 준수를 강요하여 위법행위가 있을 때 예정된 어떤 결과가 실현되는 것을 의미

문화규범: 정의라는 법의 이념을 구현하고자 하는 인간들의 문화적 산물

법의 본질

법률 : 일반적으로 법과 법률을 같은 뜻으로 사용되고 있음(법+령+시행세칙등을 일반적으로 법률이라 함)

but, 엄격한 의미에서 법률은 입법기관인 **국회의 의결을 거쳐 대통령이 공포한 것**을 말함

법규 : 법규범의 의미로 사용될 수 있으나, 직접 **국민의 권리·의무에 대한 사항을 규정한 법**을 말함

법의 구조

행위규범 : 작위(어떤 행위를 하도록 명령) + 부작위(어떤 행위를 하지 말도록 금지)하는 관계를 규정하는 규범
살인하지 말라(1차적 규범)

재판(강제)규범 : 행위규범이 정하고 있는 명령 또는 금지를 위반하는 경우 **강제력이 발동**
~~5년 이상 징역에 처한다-형법 제250조(2차적 규범)

조직규범 : 공동사회를 운영하기 위하여 필요한 조직체의 구성과 운영에 관한 규범. 수범자는 국가기관의 구성자.
법원조직법, 정부조직법 등

법과 사회규범

도덕 : 사회의 존속을 위하여 필요한 가치의 기준으로 인간의 양심에 바탕. 강제성이 없음

법과 도덕 : 항상 일치하는 것은 아니며, 도덕의 영역은 법의 영역보다 넓음

일원론(자연법론) : 법은 궁극적으로 도덕에 기초하고 합치되어야만 법으로서의 효력을 갖음.

부정당한 법이란 있을 수 없음.

이원론(법실증주의) : 구체적으로 존재하지 않는 법은 없다. 악법도 법. 법의 내용이 도덕에 반하더라도 법은

◆법(法)과 도덕의 차이점

구분	법	도덕
1	타율성	자율성
2	강제성 → 법은 위반 시 국가권력에 의해 강제적으로 그 실현이 집행	비강제성 → 위반 시 사회적 비난만 따름
3	외면성 → 법은 인간의 외면적 행위를 규율	내면성 → 개인의 양심 속에서 스스로의 결단에 의해 이루어짐
4	양면성 → 법은 권리와 의무를 동시에 강조(쌍면성)	편면성 → 도덕은 권리와 의무 중 의무를 강조(일면성)
5	목적 : 정의(正義)의 실현	목적 : 선(善)의 실현

“법은 도덕의 최소한이다” - 강제할 필요 있는것만 법으로!

“법은 법이념에 봉사한다는 의미를 지니는 현실이다”

- 법은 행위를 규율, 도덕은 내심의 규범

도덕의 강제 : 지배적인 도덕을 법으로 강제.

존속살해죄의 가중처벌 - 형법 제250조 제2항

간통죄의 처벌 - 헌재 위헌결정으로 효력상실

동성동본 혼인금지 - 헌법불합치로 폐지. 개정됨.

법의 윤리화 현상 : 착한 사마리아인 조항

성경에서 유래. 도덕적 의무 위반에 대해서 법적으로 처벌하겠다는 것.

관습 : 어떠한 행위가 사회구성원 사이에 오랜 세월을 걸쳐 반복됨으로써 사회적 행위의 기준으로 인정된 것.
비조직적 사회의 규범. 관습 위범에는 사회적 비난에 그침.

법과 관습의 관계 : '공서양속', '사회상규', '선량한 풍속'. 법에 포함되기도 하고, 법적 확신을 얻어 '관습법'이라는 형태로 법규범화가 됨.

서울이 수도라는 것은 관습헌법. 제정헌법이 있기 전부터 전통적으로 존재하여 온 헌법적 관습.

법과 종교

신정일치 - 고대. 종교가 국가, 사회를 지배
정교분리 - 근세 이후. 법은 국가법을 의미. 종교는 종교 내부의 자치법으로서 효력을 갖게 됨.
종교의 자유 - 현대. 대부분의 국가과 정교분리. 헌법에서 종교의 자유를 인정.

법의 목적

법은 무엇을 위해 존재하는가? 법이 추구하고, 법이 실현해야 할 궁극적·이상적 가치
법 이념의 3요소 : 정의 + 합목적성 + 법적 안정성

정의

아리스토텔레스의 정의론 : 정의의 본질은 **평등**.
평균적 정의 : 모든 인간을 동등하게 취급(절대적 평등). 사법의 영역에서 중시(노동과 임금, 범죄와 형벌...)
배분적 정의 : 능력, 공헌도에 따라 차등 대우(상대적·비례적 평등). 공법의 영역에서 중시(누진세, 가중처벌)

합목적성

개념 : 목적에 맞도록 방향을 정하는 것.
법의 경우 : 그 사회가 추구하는 지배적 가치관이나 이데올로기(목적)에 일치해야 하는 것

기능 : 법이 추구하는 정의를 실현시켜 줄 **기준**이 필요.
추상적인 정의를 구체화하여 법의 이념(목적)을 **현실화**하는 기능.

정의 : 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 취급하는 **추상적 이념**
합목적성 : 같은 것과 같지 않은 것을 구별하여 주는 **구체적 기준**

합목적성의 **상대성** : 사회의 지배적 가치관은 시대에 따라 달라진다.
자유주의 국가 : 개인의 자유를 최상의 가치로 결정
전체주의 국가 : 민족이나 국가와 같은 단체에 최상의 가치를 설정
현대국가 : 개인 이익과 전체 이익의 조화를 통하여 공공복리의 증진(사회적 약자의 보호)을 법의 이념으로.

법적 안정성

의의 : 법에 의해 보호받고 있어서 구성원들이 **법을 믿고 안심하고 행동할 수 있는 상태**.
기능 : 법의 제1차적 기능은 질서를 유지하고 분쟁이 발생한 경우에 평화를 회복하고 유지.

> **법 자체의 안정성 + 사회질서의 안정성**

조건 : 법의 내용이 **명확**해야 함
실제 **실현** 가능한 것이어야 함.
쉽게 변경되어서는 아니 되며, 특히 입법자의 자의에 의해 영향을 받아서는 아니 됨.
국민의 의식, 즉 **법의식에 합치**되는 것이어야 함.

헌법 제37조 제2항

국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장, 질서유지, 공공복리를 위하여

↳ **합목적성**

필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며

↳ **법적 안정성**

제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

↳ **정의**

실정법상 법정 안정성을 위한 제도 : 민법상의 소멸시효·취득시효, 형법상 공소시효 등

법과 이념 사이에 충돌이 있을 수 있음.-----^ 참고

법원(法源)

: 법 규범이 어떠한 모습으로 존재하는가 하는 법의 존재형식 또는 법의 인식근거를 의미

성문법(제정법) : 문서의 형식을 갖추고, 일정한 절차와 형식에 따라서 권한 있는 기관이 제정·공포한 법

> 헌법, 법률, 명령, 규칙, 조례, 특약

불문법 : 성문법 이외의 법으로, 문장으로 표현되지 않으며, 일정한 법제정기관에 의한 소정의 절차를 거치지 않고 생성.

> 관습법, 판례법, 조리

법계(法系)

대륙법계 : 독·프 중심의 법계. 성문법주의. 로마법 흡수, 제정법. 법관은 법전의 조종자. 일원적 성격

영미법계 : 영·미 중심의 법계. 불문법주의. 로마법 영향 약함. 판례법. 법관은 판례의 창조자. 이원적 성격

구분	성문법	불문법
장점	• 법의 존재와 의미가 명확함 → 예측 가능하기 때문에 법적 행동에 편리함 • 법적 안정성을 기할 수 있음 • 입법 기간이 짧음 • 외국법의 계수와 법체계의 통일이 용이	• 구체적 현실에 맞게 융통성 있는 법적용이 가능 • 입법자의 전횡을 예방할 수 있음
단점	• 문장의 불완전성으로 법해석의 문제가 발생 • 문장화·조문화되어 있기 때문에 사회변동에 능동적으로 대처하기 어려움 • 법이 고정화되기 쉬움	• 법의 존재와 의미가 불명확 • 법의 내용을 객관화하기 곤란하여 법적 변동의 예측이 어려움 • 외국법의 계수와 법체계의 통일이 어려움

불문법에서는 판사+배심원 체제.

계수 : 이어받다

성문법

1. **헌법** : 국민의 기본권을 보장하고 국가의 통치구조의 원리를 규정하는 국가의 근본규범

법체계 속에서 최고의 단계에 위치(국가의 최상위 규범)

모든 법 제정은 근거가 헌법. **헌법을 만드는 힘은 오직 국민에게 있음.**

하위법의 정립근거나 한계, 해석기준이 됨.

법률 개정보다 엄격한 절차 필요.

2. **법률** : 국회에서 의결되어 대통령이 서명·공표하여 제정된 법.

국회는 유일한 입법기관으로서 국민의 기본권에 관한 사항을 법률로서 정함

헌법은 국민의 권리의무에 관한 사항, 기타 중요사항은 반드시 법률로 규정할 것을 요구함. > 입법사항

법률 제정 절차 : 법률안의 제출

-> 법률안의 의결

-> 공포

by 국회의원, 정부

재적의원 과반출석 과반찬성

15일 이내 대통령임.

공포 후 20일 후에 효력 발생

3. **명령·규칙** :

3-1) **명령** : 국회의 의결을 거치지 않고 **행정주체(행정기관)**가 법률에 의하여 제정하는 **위임 입법**

제정주체에 따른 구분 : 대통령령, 총리령, 부령

명령 성질에 따른 구분 : 위임명령, 집행명령

위임명령 : 법률에 의해 위임받은 사항. 법률의 내용을 보충

집행명령 : 법규를 집행하기 위하여 필요 세칙에 관한 사항을 정함. - by 법원. 집 빠라... 등

3-2) **규칙** : 국가기관의 자율성을 존중하여 그 소관 사무에 관하여 법률에 저촉되지 않는 범위 내에서 내부 규율과 사무처리에 관하여 제정하는 법규

헌법은 권력분립의 이념에 따라 국회, 대법원, 선관위, 헌재 등에게 각각 규칙제정권 부여.

명령과 같은 효력. 자치법규로 다루어지는 규칙과는 구별됨.

4. **자치법규** : 지방자치단체가 법령의 범위 안에서 제정하는 자치에 관한 법규

조례 : 지방의회가 법령의 범위 내에서 그 사무에 관하여 의결로 제정

규칙 : 지방자치단체의 장이 법령과 조례의 범위 내에서 그 사무에 관하여 제정

5. **국제조약과 국제법규** :

조약 : 문서에 의한 국가 간의 협의 - 협약, 협정, 규정, 의정서, 헌장, 규약, 교환 각서 등등....

헌법에 의하여 체결·공표된 조약, 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 동일한 효력을 가짐.

성문법 간의 상호관계

상위법 우선의 원칙 : 헌법 > 법률 > 명령·규칙 > 자치법규(조례·규칙)

상위 법규에 저촉되는 하위 법규는 그 효력을 상실

특별법 우선의 원칙 : 동일한 사항에 대하여 특별법은 일반법에 우선하여 적용(상대적인 개념!)

신법 우선의 원칙 : 법령이 새로 제정되거나 개정된 경우 신법은 구법에 우선함

법률불소급의 원칙 : 법적 안정성의 확보를 위하여 소급효가 없다는 원칙

불문법

1. **관습법** : 일정한 관행이 반복되어 대다수의 사람들로부터 법적 확신 내지 법적 인식을 얻은 것.

성립요건

1) 어떠한 관행이 존재할 것

2) 그 관행이 선량한 풍속, 기타 사회질서에 반하지 않을 것

3) 그 관행을 국민 일반이 법규범으로서의 의식을 가지고 지킬 것

효력 : 관습법은 성문법을 보충하는 효력이 있음. 법령의 규정에서 명문으로 인정하는 경우이거나,

법령에 규정이 없는 사항에 관하여서만 성립 가능.

민법 제1조 : 민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고, 관습법이 없으면 조리에 의함.

형법 : 죄형법정주의 원칙상 관습법 효력 인정X

상법 제1조, 민법 제 185조 ~~(PPT 62쪽 참고)

2. **판례법** : 법원의 판결을 통하여 형성된 법이론이나 법원칙인 판례의 형태로 존재하는, 성문화되지 않은 법규범

재판의 선례를 말하며, 그 선례가 그 후의 판결을 구속할 때 그 판례는 법원으로서 성립

영미법계 국가 : 선례 기속의 원칙이 확립되어 제1차적인 법원. 그 구속력과 법규성이 인정됨.

대륙법계 국가 : 성문법주의로 인하여 법의 보충적 기능만을 담당.

3. **조리** : 사람의 건전한 상식으로 판단할 수 있는 사물의 본성 또는 본질적 법칙

경험칙, 사회통념, 사회적 타당성, 공서양속, 신의성실, 정의, 형평의 원칙 등의 모습으로 표시

법의 흠결 시에 법관에 의하여 최종적으로 원용되는 법원.

민사관계에서 : 성문법과 관습법이 없다고 하여 법관은 '법의 흠결'을 이유로 재판을 거부할 수 없음

형사관계에서 : 죄형법정주의에 의하여 조리의 법원성이 부정(인정X)

법의 분류

1. 법의 보편성 인정여부

자연법 : 모든 시대와 사회에 **보편타당**하게 적용 가능. 보편적이고 항구적(영구적)인 법. 시대, 민족 국가 초월.

실정법 : 특정한 시대와 사회에서 구체적이고 실질적인 효력을 지닌 법. 현실적으로 시행되고 있는 법.

성문법은 물론이고 불문법까지 포함

> 둘은 **상호보완적인** 관계!

자연법은 실정법을 제정하는 기준+부당한 실정법을 개정하는 기준. 자연법은 실정법을 통해 구체화.

2. 법을 제정하는 주체와 적용범위

국내법 : 한 국가에 의하여 인정되고 그 국가의 주권이 미치는 범위 내에서 국가와 국민 또는 국민 상호간의 권리·의무관계를 정하는 법

국제법 : 다수 국가들 사이에 적용되는 법. 국가 상호간의 관계, 국제 조직 등에 대해 규율하는 법.

조약(문서로 합의), 국제법규, 국제관습법이 있음.

+국제사법은? (어느 나라의 법을 적용할까?) ==> **국내법**이다!

국제사법 : 외국적 요소가 있는 법률관계에 관하여 국제재판관할권에 대한 원칙과 준거법을 정한 법.

ex) 한국에 거주하고 있는 미국인 부부의 이혼에 대한 케이스...

3. 공법, 사법, 사회법

공법 : 국가의 조직과 기능 및 공익작용을 규율하여 **공적인 생활관계**를 형성하는 법.

공권력을 중심으로 규율됨. **상하의 수직적인** 관계가 성립하는 경향.

헌법, 행정법, 형법, 형사소송법, 민사소송법

사법 : 개인 상호 간의 권리와 의무 관계를 규율하는 법

개인 간의 대등한 법률관계를 다루기 때문에 **횡적·수평적** 관계가 성립하는 경향.

민법, 상법

사회법 : 자본주의의 문제점(사회적 약자 보호)을 해결하기 위해 국가가 적극적으로 개입.

공법과 사법 성격 모두. 제3의 법영역(**사법의 공법화**). 사유재산, 계약자유의 원칙을 부정하지X. 부분적 수정

노동법 : 근로자의 생존권 확보를 보장하는 법

경제법 : 국민경제의 균형 있는 경제발전을 꾀하기 위한 법.

사회보장법 : 국민의 생존권을 확인, 사회적 위험으로부터 국민의 생활을 보장하기 위한 법

4. 실체법과 절차법

실체법 : 권리·의무의 **실체**. 즉 권리나 의무의 발생, 변경, 소멸, 성질, 내용 및 범위 등에 관하여 규정한 법.

헌법, 민법, 형법, 상법 등

절차법 : 권리·의무를 실현하는 **절차**. 실체법에 의해 규정된 권리와 의무를 실현하기 위한 수단과 방법을 규율.

민사소송법, 형사소송법, 행정소송법 등

실체법-목적, 절차법-수단

법원은 실체법이 없다는 이유로 재판 거절 불가.

but, **절차법이 없을 때는** 재판을 할 수 없음.

법률불소급의 원칙 : 실체법은 신법에 소급효를 인정하지 않는 것이 일반적 원칙.

절차법은 특별한 규정이 없는 한 신법 적용(이미 과거에 일어났어도 소급 적용O)

5. 일반법과 특별법

일반법 : 제한 없이 보편적으로 적용되는 법

특별법 : 특정한 사람, 장소, 사물에 대하여 제한적으로 적용. 일반법으로 규율하기 부적절한 경우 특별법 필요.

★일반법과 특별법은 **상대적인 개념**★

민법 << 상법 << 은행법, 보험업법

특별법 우선의 원칙 : 동일한 사안에 대해 서로 다르게 규정하고 있으면 **특별법이** 일반법에 우선하여 적용

6. 원칙법과 예외법

원칙법 : 법의 적용대상에 대하여 **일반적으로 적용되는 법**

예외법 : 원칙법의 예외를 인정함으로써 **원칙법을 배제**하고 적용되는 법. - 태아에 관한 규정

동일한 법률 중에서 또는 동일한 조문 중에서 구별되는 것이 보통. 예외를 지정한 법.

7. 강행법과 임의법

강행법 : 당사자의 의사로 배제할 수 없고 당연히 **강제, 적용되는 법**

헌법, 형법, 행정법 등의 **공법**은 대부분 강행법

~하여야 한다, ~하지 않으면 ~하지 못한다

임의법 : 당사자의 의사로 그 적용을 배제할 수 있는 법

당사자의 의사로 그 **적용을 배제**할 수 있는 법

사적자치를 원칙으로 하는 민법, 상법 등의 **사법**은 대부분 임의법에 속함

8. 고유법과 계수법

고유법 : 국가, 민족 고유의 사회적·역사적 흐름 속에서 **자연적으로** 생성되어 온 법

계수법 : 타국에서 생성, 발달한 법률제도와 사상을 받아들여 이것을 자료로 하여 성립한 법

상대적인 개념. 계수법도 오랜 시일 경과하면 소화·흡수되면 고유법으로서의 성질을 가지게 됨.

법의 효력

법의 실질적 효력

: 법 규범을 현실적으로 실현시키고 복종시킬 수 있는 힘

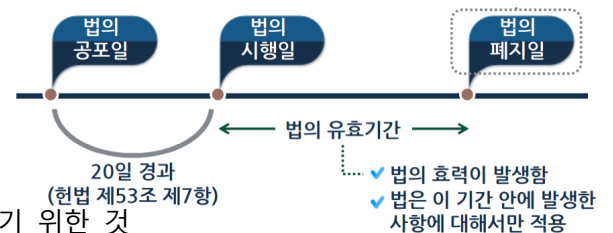
행위규범 : 법의 내용을 실현하는 강제력

강제규범 : 법이 사회를 구속하는 힘

규범적 타당성 : 내용뿐 아니라 **규범으로서 타당성**을 가지고 있어야 함.

사실적 실효성 : 법이 **현실로 지켜져** 실현되는 강제력

>>타당성과 실효성은 필수적이다! 불가분의 관계.



법의 형식적 효력

1. 법의 시간적 효력

공포 : 법의 성립과 그 내용을 국민들에게 주지(알리기)시키기 위한 것

법의 주지기간(**시행유예기간**) : 공포일로부터 시행일까지의 일정한 기간

입법기관에서 제정된 법은 해당 법령의 **부칙**에 효력의 발생시기를 규정하는 것이 일반적

법의 효력 소멸

명시적 폐지 : 그 **시행기간**을 정해놓은 경우 그 기간이 종료된 때에 폐지.

신법에서 **명시규정**으로 구법을 폐지한다고 규정한 경우 구법 폐지.

묵시적 폐지 : 신법 **우선의 원칙 적용**. 신·구법이 모순·저촉되면 구법은 효력을 상실

법의 목적사항이 완료되어 법의 효력이 소멸되는 경우

법률불소급의 원칙 : 시행 후에 발생한 사항에 관해서만 적용되고, 소급하여 적용하지 못함.

예외) 신법을 소급하여 적용하는 것이 정의에 부합하는 경우, 불이익을 제거하는 경우 예외적 인정

>>유리한 경우는 예외적으로 소급 적용 인정

2. 법의 대인적 효력

속지주의 : 地 기준으로 영토를 기준으로 적용

: 국가의 **영토를 기준으로** 그 영토 내에 거주하는 내·외국인 불문, **그 나라의 법**을 적용할 수 있음.

예외) 헌법상의 권한 : 참정권, 병역의무

타국에 있는 타국인에게 자국법 적용 : 내란죄, 외환죄, 국기에 관한 죄, 통화 및 유가증권에 관한 죄(형법상 보호주의)

외교상 특권과 면제

공해상에서 선박에 대한 관할권(**속지주의에 대한 확대**)

속인주의 : 人 국적을 기준으로 적용

: 국적을 가지는 자는 외국에 있는 자에게도 국내법을 적용한다는 것

예외) 국가정책상 특수한 신분을 가진 자에게 국내법의 적용 배제(대통령, 국회의원의 형사상 특권)

국제법상의 원칙 : 속지주의가 원칙 + 보충적으로 속인주의

3. 법의 장소적 효력

속지주의 원칙 : 한 국가의 법은 원칙적으로 그 국가의 전체 영역(영토+영해+영공)에 걸쳐 적용함.

국가의 통치권은 그 영역 내에 있는 내·외국인을 구별하지 않고 적용됨이 원칙.

예외)

1. 속인주의 적용 : 외교 특권을 누리는 자, 국제사법에 의하여 본국법의 적용을 받도록 하는 자

2. 영토의 일부 적용 : 지자체의 조례와 규칙은 해당 지자체에만 적용. 도시계획법 특정 지역만 적용

3. 속지주의의 확대 : 타국의 영역 내에 있는 자국의 항공기, 선박 등은 자국영역의 연장으로 봄

법적 제재

법적 제재란?

: 국가권력을 바탕으로 법의 목적을 달성하고 실효성을 확보하기 위해 법 위반자에게 가해지는 **법적 통제**

강제성과 그 본질적 요소로 함. 법적 근거와 적법한 절차에 의해서만 가능. 사적 제재와 구별됨.

필요한 범위 내에서만 행사되어야 함.

헌법상의 제재 - 국가권력에 대한 법적 통제

탄핵제도 : 헌법이나 법률을 위배한 경우 국회에서 탄핵의 소추를 의결하고 헌재가 이를 심판함.

정당에 대한 해산

해임 건의 : 국무총리와 국무위원에 대한 해임 건의

국정조사, 국정감사

국회의원에 대한 징계 등...

행정법상의 제재 - 행정법규를 위반한 자에 대한 제재

공무원에 대한 제재 :

징계처분 - 파면, 해임, 정직, 감봉, 견책

직위해제 - 공무원 신분은 유지하되 직위를 부여하지 않는 것

행정처분 - 징계처분 직전의 경미한 행정법규 위반. > 주의, 경고, 공익봉사

일반 국민에 대한 제재 :

행정상 강제집행 - 강제적으로 이행시키기 위함 > 대집행, 집행벌, 직접강제, 행정상의 강제징수
행정상 즉시강제 - >불심검문, 강제격리
행정벌 - 행정형벌 - 형법상의 형벌을 과하는 행정벌. 통고처분(법칙금 납부)나 즉결심판.
- 행정질서벌 - 가벼운 위반에 대해 금전적 부담(과태료 부과)을 주는 행정벌

형법상의 제재 - 형법 기타 형벌법규에 위반한 자에 대하여 사법적 절차에 의하여 부과하는 제재

죄형법정주의 원칙 : 법률이 없으면 범죄도 없고, 법률이 없으면 형벌을 부과할 수 없다!

생명형 : 사형

자유형 : 징역, 금고, 구류

명예형 : 자격상실, 자격정지

재산형 : 벌금, 과료, 몰수

사법(私法)상의 제재 - 민법, 상법 등 사법의 규정에 위반한 자에 대하여 가하는 제재

손해배상 - 타인이 받은 손해를 전보하여 손해가 없는 것과 같은 상태로 하는 것

채무불이행, 타인에게 손해를 가한 경우(불법행위)

>> 금전배상주의 원칙

강제집행 - 채권자의 청구에 의해 국가의 공권력으로 강제적으로 이행하는 제재

실권 - 법률상의 자격 또는 권리를 상실하게 하는 제재

국제법상의 제재 - 국제법을 위반한 경우 상대국에 대한 경제단교, 외교단절, 무력제재, 전쟁 등의 제재

단점 : 국내법상 제재에 비해 강력한 강제적 제재수단을 갖추지 못함.

>> UN(국제연합)이라는 국제조직과 각 국가들 간의 집단방위조약이 세계의 평화와 안전의 유지에 기여

법의 적용과 해석

법 적용의 과정

삼단 논법의 형식

1. 대전제(적용될 추상적 법규)

형법 제250조 제1항 : 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다

2. 소전제(구체적 사건. 사실의 확정)

법이 적용될 구체적 사실. 살인 행위

3. 결론(판결)

>> 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역을 부과함.

사실 확정의 방법 : 사회적 사실을 있는 그대로 인식하는 것이 아니고, 법적으로 인식하는 것.

객관적 증거에 의함.

입증 : 사실의 존부에 관하여 확신을 얻게하는 자료인 “증거”를 주장. 입증책임은 주장하는 자가 부담.

추정 : 입증으로써 확정되지 못한 사실을 우선 있는 사실대로 인정. 반대증거가 제출되면 번복될 수 있음.

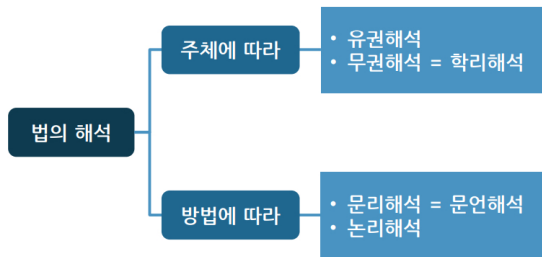
간주(의제) : 사실 여하를 불문하고 법에 의하여 사실관계를 확정하는 것. 반대증거 제출을 불허.

사실의 확정에 있어 추정보다 효력이 강함.

“~으로 본다”라고 규정한 경우

법의 해석

: 법을 구체적 사실에 적용하고자 법의 의미와 내용을 밝히고 확정하는 것



유권해석 : 국가의 권위 있는 기관에 의한 해석. 강제적인 구속력 부여. ~~강제해석, 공권해석

입법해석 : 법령의 조문 자체에 해석규정을 둬. 가장 구속력이 강한 절대적 해석

사법해석 : 법관이 재판할 때 판결문에 밝힘. 법원은 최종적인 유권해석 기관.

행정해석 : 행정기관이 법을 집행하기 위하여 필요한 경우.

무권해석 : 대학, 연구소 등 학자나 일반 사인에 의한 해석. 구속력X, ~~학리해석

법조문의 문언에 대해 그 의미를 밝혀 법 적용의 기준을 제공.

>>보통 법의 해석이라고 하면 무권해석을 말함.

문언해석(문리해석) : 법조문에서 언어적 의미나 문장에 중점을 두는 언어학적 해석방법. 성문법 해석의 출발점.

ex) 민법 제108조에서 “통정”을 “서로 합의하여”로 해석하는 것

논리해석 : 법의 객관적 의미를 찾으려는 해석. 문리해석을 토대로 완전하게 할 수 있는 것.

1. 축소해석(제한해석) : 의미를 좁혀서 해석하는 방법
2. 확장해석 : 보통의 일반적 의미보다 넓게 해석하는 방법
3. 반대해석 : 법문이 정하는 요건과 반대의 요건이 존재하는 경우, 법문이 정하는 반대의 효과를 발생하는 것이라고 해석하는 방법
4. 물론해석 : 법문이 일정한(일반적인)사항을 규정하고 있는 경우에 그 이외의 사항에 대해서도 사물의 성질 상 당연히 그 규정에 포함되는 것으로 해석하는 방법
5. 유추해석 : 직접적인 명문의 규정이 없는 경우, 이와 유사한 사항에 대하여 법규정을 적용하는 방법

민사법에서는 유추해석이 인정됨. 법원이 법규의 결함을 이유로 재판 거부할 수 없기 때문.

형법과 유추해석의 금지 : 죄형법정주의에 입각하여 유추해석 금지.

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| ① 제1단계 해석방법 | 문리해석 |
| ② 다른 법규의 제정형식을 취하는 해석 | 입법해석 |
| ③ 가장 구속력이 강한 절대적 해석 | 입법해석 |
| ④ 최종적인 유권해석기관 | 법원 |
| ⑤ 법의 이념과 정신을 객관화하는 데 중요시하는 해석 | 논리해석 |
| ⑥ 유권해석 | 공권적 해석 |
| ⑦ 학리해석 | 무권해석 |

법률관계와 권리·의무

법률관계

: 법에 의하여 규율되는 생활관계

-> 매매관계, 혼인관계, 상속관계 등과 같이 법에 의하여 규율되는 생활관계

* 궁극적으로는 사람과 사람의 관계.

* 법에 의하여 **보호(권리)**되는 자와 법에 의하여 **구속(의무)**되는 자의 관계로 나타남.

>> 법률관계의 주된 내용은 **권리**와 **의무**

중세봉건사회 : 상하의 신분제도를 배경으로 한 '의무 본위'(기준) - 의무만 有

근대사회 : 자유와 평등의 시민사회로 '권리 본위'

현대사회 : 자유주의, 개인주의, 자본주의 경제의 모순 대두로 '의무 중시'

권리

: 일정한 이익을 누리게 하기 위하여 법이 인정하는 힘

권리와 구별해야 하는 개념

권한 : 타인을 위하여 일정한 법률효과를 발생하게 하는 행위를 할 수 있는 **법률상의 자격**

권능 : 권리의 내용을 이루는 **개개의 법률상의 힘**

권원 : 어떤 법률적 또는 사실적 행위를 하는 것을 **정당화시켜 주는 근거**

반사적 이익 : 일정한 행위를 명함으로써 그 반사적 효과에 의하여 **다른 자가 누리는 이익**

공권의 분류

국내법상의 공권

국가적 공권 : 국가 또는 공공단체가 국민에 대하여 갖는 권리.

ex) 입법권, 사법권, 행정권 행정조직권, 재정권, 형벌권, 경찰권...

개인적 공권 : 개인이 국가나 공공단체에 대하여 갖는 헌법에 의하여 보장되는 권리

ex) 자유권, 생존권, 청구권, 참정권

국제법상의 공권 : 국제법상의 주체로서 가지는 권리

ex) 독립권, 평등권, 자위권, 교통권

사권의 분류

*내용에 따른분류

재산권 : 금전적으로 평가되는 경제적 가치를 누릴 수 있는 권리

물권 - 객체를 지배해서 이익을 얻을 수 있는 권리

채권 - 채권자가 채무자에 대하여 일정한 이행행위(급부)를 요구할 수 있는 권리

지적재산권 - 정신적·지능적 창조물인 무형의 이익을 목적으로 하는 권리

인격권 : 인격의 주체인 개인이 갖는 권리

가족권 : 가족 간의 신분관계에서 발생하는 권리 친족권, 상속권

사원권 : 단체의 구성원, 즉 사원이 그 구성원이라는 지위에서 단체에 대하여 가지는 권리

*작용(효력)에 따른 분류

지배권 : 다른 사람의 행위를 개입시키지 않고 일정한 **객체**에 대하여 **직접 지배력**을 발휘할 수 있는 권리

청구권 : 특정인이 특정 타인에 대하여 **일정한 행위(작위·부작위)**를 **요구**할 수 있는 권리

형성권 : 권리자의 **일방적인 의사표시**에 의하여 법률관계를 발생·변경 또는 소멸시키는 권리

항변권 : **청구권**의 작용을 **저지**할 수 있는 권리. but **청구권을 인정하면서 그 작용만 저지**하는 것임.

-> 청구권의 성립을 부정하거나 소멸을 주장하는 것은 아님! ex)가처분신청

*작용(효력)에 따른 분류

절대권 : 모든 자에게 주장할 수 있는 권리

물권, 지적재산권...

상대권 : 특정인에 대해서만 주장할 수 있는 권리

채권

*권리의 이전성(양도여부)에 따른 분류

일신전속권 : 권리의 성질상 타인에게 귀속(이전)할 수 없는 권리

비전속권 : 자유로이 이전(양도나 상속)이 가능한 권리

*권리의 독립성에 따른 분류

주된 권리 : 다른 권리에 대하여 종속관계에 있지 않고 완전히 독립된 권리

종된 권리 : 다른 권리의 효력으로 담보하거나 또는 증가시키기 위해 그 권리에 종속하는 권리

의무

: 본인의 의사와는 무관하게 일정한 행위를 해야 할(작위의무) 또는 해서는 아니 될 의무(부작위의무) 법률상의 구속

권리만 있고 의무가 없는 경우나, 권리는 없고 의무만 있는 경우도 있음

의무와 구별하여야 하는 개념

간접의무(책무) : 의무를 부담하는 자가 반드시 이행하여야 하는 것은 아니지만, 의무를 이행하지 않으면 유리한 법적 지위의 상실과 같은 불이익을 입게 되는 의무

의무의 종류 : 공법상의 의무, 사법상의 의무, 사회법상의 의무

권리의 행사와 의무의 이행

권리의 행사 : 권리의 내용을 구체적으로 실현하는 과정

권리행사의 한계

헌법상의 한계 : 재산권의 행사는 공공복리에 적합하도록 하여야 한다.

... 국가안전보장, 질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며...

민법상의 한계 : 신의성실의 원칙 - 상대방의 믿음을 헛되이 하지 않도록 성의를 가지고 행동하는 것

권리남용금지의 원칙 - 정당한 권리의 행사로써 볼 수 없는 경우 법률효과가 발생하지 않음

의무의 이행 : 의무자가 의무의 내용으로 실현하기 위한 행위를 하는 것

의무를 발생시킨 계약 또는 법률규정에 맞게 하여야 하며, 신의에 좇아 성실하게 하여야 함.

의무를 이행하지 않을 경우 -> 강제배상, 손해배상, 형사상의 제재

헌법의 의의

헌법이란?

: 정치적 공동체의 존재형태와 기본적 가치 질서에 관한 국민적 합의를 법규법적인 논리체계로 정립한 **국가의 기본법**. >> 그 시대의 정치적 이념과 시대사상을 반영하는 역사적 생성물

: 국가의 통치조직과 작용, 국가기관 상호간의 관계, 국가와 국민과의 관계에 관한 근본규칙을 정한 **최고법**
>> 국가의 **기본적 법질서**를 의미. **공법·국내법**에 속함.

헌법의 이중성

법규범으로서의 헌법 : 헌법의 본질을 국가생활에 있어야 할 당우로서의 법규범으로 봄

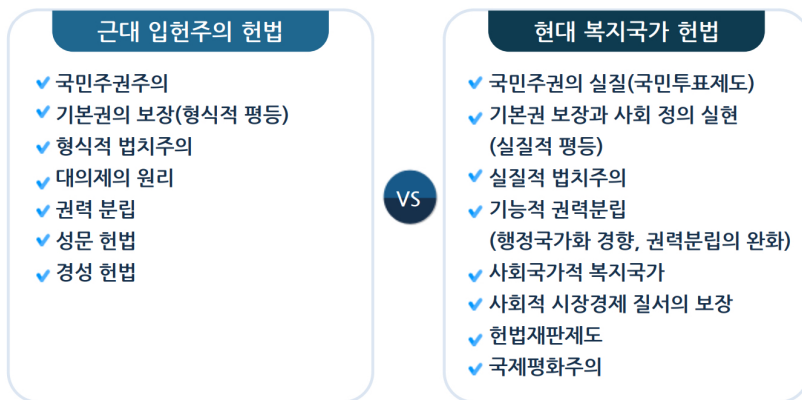
정치적 사실로서의 헌법 : 헌법의 본질을 국가의 정치적 통일 및 사회질서의 구체적 상태로 봄.

헌법의 역사적 변천

본래의 의미의 헌법 : 국가가 존재하는 한 어떠한 형태로든 존재하는 헌법

근대 입헌주의의 헌법 : 개인의 자유와 권리의 보장, 권력분립에 의한 국가권력 남용을 억제

현대 복지국가 헌법 : 복지국가의 이념을 바탕.



헌법의 특성

사실적 특성 : 정치성 + 역사성 + 이념성

규범적 특성

최고규범성 : 한 국가의 실정법 체계 속에서 최고의 단계에 위치하는 규범

조직규범성 : 국가의 조직을 구성하고 그 권한을 부여하는 수권 규범

권력제한 규범성 : 국가기관에 부여된 권력의 행사방법을 규정하고 적절히 행사되는지를 통제하는 규범

기본권 보장 규범성 : 기본적 인권을 확인하고 보장하는 규범

생활규범성 : 가치규범, 행동규범이 됨

헌법의 분류

by 제정주체

흙정헌법 : 군주주권론을 기초로 군주의 일방적 의사에 의해 제정

민정헌법 : 국민이나 국민대표기관에 의해 제정

협약헌법 : 군주와 국민대표 간의 타협에 의해 제정

국약헌법 : 국가(연방·주) 간의 합의에 의해 제정

by 존재형식

성문헌법 : 헌법이 단일·통일된 헌법전으로 존재

불문헌법 : 헌법전의 형식이 아닌 주요 부분이 관습법 등에 의하여 성립된 것

by 개정절차의 난이도

경성헌법 : 헌법개정을 일반 법률개정 절차보다 엄격하게 하는 경우

연성헌법 : 헌법개정을 일반 법률개정 절차와 동일하게 하는 경우

헌법의 제정과 개정

헌법제정권력

: 국가의 근본법인 헌법을 창조하는 힘. 국민주권사상의 확립에 따라 국민에게 헌법제정권력이 귀속됨
특징

시원성과 창조성 : 헌법을 시원적(시작)으로 창조하는 힘

불가양성 : 누구에게도 양보할 수 없음

단일불가분성 : 분할할 수 없음

항구성 : 한번 행사한다고 하여도 소멸되지 않음.

헌법의 개정

: 헌법에 규정된 개정 절차에 따라 헌법의 기본적 동일성을 유지하면서 헌법의 내용을 수정·삭제·추가.
헌법의 현실적 규범력을 유지하기 위하여 헌법개정이 불가피함.

but, 불문헌법 국가(영국)인 경우 헌법개정의 실익이 없음

동일성을 유지하는 범위 내에서의 변경이라는 점에서 헌법 제정과는 구별됨

증보형식 : 헌법의 개정 조항만을 추가·증보하는 형식으로 기존의 조항은 그대로 유지. - 미국 연방헌법

수정형식 : 헌법의 기존 조항을 수정·삭제·삽입하는 형태 - 우리나라 헌법.

헌법 제128조 제2항 : 대통령의 임기연장 또는 중임 변경을 위한 헌법개정은 그 헌법개정 제안 당시의 대통령에 대하여는 효력이 없다.

우리나라 헌법의 개정 절차

1. 제안
2. 공고
3. 의결
4. 국민투표
5. 공포

대한민국 헌정사

대한민국 헌법의 제정

1948. 5. 10. 198인의 국회의원 선출

1948. 7. 17. 건국헌법 제정 공포, 즉일로(즉시) 시행

내용 : 민주공화국, 국민주권, 기본권 보장, 사기업에 있어서의 근로자의 이익분배균점권, 단원제 국회
대통령과 부통령 국회선출...

9차례의 개헌이 이루어짐

헌법전문

헌법의 성립유래, 헌법제정권자, 헌법의 제정목적, 헌법의 기본원리

헌법전문의 법적 성격

최고규범성 : 모든 법규범의 내용을 한정하고 그 타당성의 근거가 됨

법령의 해석기준 : 헌법 본문과 기타 법령의 해석 기준

재판규범성 : 다수설과 헌법재판소의 입장은 헌법전문에 대한 재판규범성을 인정함

헌법개정의 한계 : 동일성을 침해하지 않는 범위 내에서 자구수정은 가능. 핵심적인 내용은 전면개정 불가.

헌법전문의 주요내용

대한민국의 건국이념(3·1운동, 임시정부 법통, 4·19 이념의 계승)
국민주권주의
자유민주적 기본질서의 확립
기본권의 존중
국제평화주의와 평화통일의 원리
정의로운 복지사회의 구현

전문내용이 아닌 것

대한민국의 영토
재외국민의 보호
권력분립
정치보복의 금지
모든 헌법개정 일자
5·18 운동...

헌법의 기본원리의 의의

헌법의 이념적 기초인 동시에 헌법을 총체적으로 지배하는 지도원리

1. 국민주권의 원리 : 합리적 선거제도를 마련. 직접민주제(국민투표) 가미. 정치적 기본권 보장.
2. 법치국가의 원리 : 실질적 법치주의. 기본권 보장. 권력분립제
3. 사회(복지)국가의 원리 : 최소한의 인간다운 생활 보장. 경제질서의 규제와 조정
4. 문화국가의 원리 : 학문교육예술종교 등의 영역
5. 국제평화주의와 평화적 통일의 추구 : 침략적 전쟁의 부인. 외국인의 법적 지위 보장, 국제법 존중, 평화통일

기본권 총론

기본권의 의의

: 국민으로서 당연히 누릴 수 있는 권리. 헌법에 의해 보장되는 권리. 인권의 개념과 거의 동일시.

기본권의 법적 성격

주관적 공권성 : 국가권력에 대한 방어적 권리로서, 국민이 국가권력에 대하여 가지는 일정한 권리
자연권성 : 인간이 태어날 때부터 인간에게 주어진 원리로 이해
양면성 : 주관적으로는 개인을 위한 대국가적 공권, 객관적으로는 국가의 기본적 법질서의 구성 요소

기본권의 분류·유형

1. 포괄적 기본권 : 인간의 존엄과 가치, 행복추구권, 평등권
2. 자유권적 기본권 : 신체의 자유권, 사회·경제적 자유권(거주이전, 직업선택..), 정신적 자유권(양심,종교,창작...)
3. 정치적 기본권(참정권) : 선거권, 공무담임권, 국민투표권
4. 청구권적 기본권 : 청원권, 재판청구권, 형사보상청구권, 국가배상청구권...
5. 사회권적 기본권 : 인간다운 생활을 할 권리, 교육을 받을 권리...

기본권의 주체

국민 : 국가의 구성원으로서 계속적 지위를 가지는 자. 보유능력+행사능력 有
외국인 : 어느정도는 기본권을 가지지만, 평등권, 자유권, 참정권, 사회권 등은 일정한 범위에서 제한
법인 : 사법상의 법인에 대해서는 기본권 주체성을 긍정. but 공법상의 법인에 대해서는 원칙적으로 부정.

기본권의 효력

대국가(對國家)적 효력 : 기본권은 모든 국가권력을 직접 구속하는 대국가적 효력을 가진.

대사인(對私人)적 효력 : **간접적 효력설**을 원칙. 사인 간 관계에 적용될 수 없는 기본권을 배제. 직접 적용할 수 있는 것은 직접 적용.

기본권의 경합과 충돌

기본권의 경합(경쟁)

단일의 기본권 주체가 국가에 대하여 **여러 기본권의 효력을 동시에 주장**하는 경우는?

- 1) 기본권이 일반법과 특별법에 동시에 규정된 경우 > **특별법 우선적용**
- 2) **직접적인** 관련이 있는 기본권을 우선 적용

기본권의 충돌

복수의 기본권 주체가 서로 **충돌하는 권익**을 실현하기 위하여 국가에 대해 각각 **자신의 기본권 효력을 주장**하는 경우

>> 법익형량의 원칙(비교 형량)과 규범조화적 해석으로 해결 - 조율해서 해결해라(by 헌재)

기본권의 제한

※**유보** : 일정 요건이나 절차를 '미리 정해두는 것'※

1. 헌법유보에 의한 기본권의 제한(헌법 직접적 제한)

헌법에서 명시적으로 기본권제한 규정을 두는 것

일반적 헌법유보 - 기본권 일반에 대한 제한을 헌법이 직접 규정(헌행헌법에 없음)

개별적 헌법유보 : 특정의 기본권 제한을 헌법이 직접 규정.

ex) 정당해산, 언론출판 자유제한, 군인·군무원의 국가배상청구권 제한

2. 법률유보에 의한 제한(헌법 간접적 제한)

국민의 기본권을 제한하고자 할 때 입법권자가 제정한 법률에 의하도록 하는 것

일반적 법률유보 : 기본권 제한의 목적이나 방법을 **일괄하여** 규정(헌법 제37조 제2항)

개별적 법률유보 : 개별적 기본권 조항에 **법률이 정하는 바에 따라** 제한할 수 있음을 명시

ex)신체의 자유, 재산권, 근로3권

기본권 제한의 원칙 : **법률에 의해서만** 제한될 수 있음 -> 일반적 법률유보

기본권 제한의 대상 : 특별히 제한 불가능한 절대적 기본권이 있지는 않음. 현행 헌법상 모든 기본권 제한 가능.

기본권 제한의 목적 : 국가안전보장, 질서유지, 공공복리

포괄적 기본권

인간으로서의 존엄과 가치(헌법 제10조)

모든 사람은 인간이라는 그 자체만으로도 존중할 만한 가치를 가지며 다른 사람에게 예속되거나 다른 사람을 위한 수단으로 이용되어서는 아니 된다. (노예 등 불가)

내용 : **객관적 헌법원리의 규범화** - 헌법질서의 방향과 기준. 헌법조항, 법령의 해석의 기준. 흠결이 문제되는 경우 보완을 위한 기준이 됨.

효력 : 대국가적 효력 + 대사인적 효력

행복추구권

소극적으로는 고통과 불쾌감이 없는 상태를 추구할 권리.

적극적으로는 안락하고 만족스러운 삶을 추구하는 권리

내용 : 행복추구의 수단이 될 수 있는 개별적 기본권. 헌법에 열거되지 아니한 권리. 헌재가 인정한 행복추

구권은 자기결정권, 일반적 행동자유권, 개성의 자유로운 발현권, 휴식권, 문화향유권 등....
효력 : 대국가적 효력 + 대사인적 효력

평등권

국가에 대하여 합리적 이유 없이 불평등한 대우를 하지 말 것과 **평등한 대우를 요구할 수 있는 권리**
법적 성격 : 포괄적 기본권성, 자연권성, 근본 규범, 개관적 법질서성, 주관적 공권성
내용 : **모든 법 앞에서의 평등**. 법 내용의 평등까지도 포함.
성별·종교·사회적 신분은 초월하여 정·경·사·문의 전 영역에 걸쳐 차별을 금지

자유권적 기본권

신체의 자유

신체의 안전성과 자율성을 제한·침해당하지 아니하는 자유. **자유권 중에서 가장 핵심적**
1215년 영국의 대헌장에서 최초로 규정.

헌법 제12조	① 죄형법정주의와 적법절차의 보장	⑤ 구속사유 고지제도
	② 고문의 금지와 불리한 진술 거부권	⑥ 체포·구속적부심사제도
	③ 영장주의	⑦ 자백의 증거능력 제한
	④ 변호인의 조력을 받을 권리와 국선변호인 제도	
헌법 제13조	① 형벌불소급·일사부재리의 원칙	
	② 연좌제의 금지	
헌법 제27조	① 형사피고인의 무죄 추정	
	② 형사피해자의 진술권	
	③ 신속한 재판을 받을 권리	

사회·경제적 자유권

거주·이전의 자유(헌법 제14조)

인간존재의 본질적 자유권으로서 **인신의 자유권**의 성질을 가지는 것으로, 자기 의사에 의해서 자유롭게 주거지를 설정할 수 있는 자유

직업선택의 자유와 밀접한 관계. 국내/외 거주·이전의 자유, 국적 이탈의 자유

직업선택의 자유(헌법 제15조)

자기가 결정한 직업에 계속적으로 종사하거나 자율적으로 변경할 수 있는 자유
직업 결정, 수행, 이탈의 자유, 자유경쟁의 자유, 겸직의 자유

주거의 자유(헌법 제16조)

거주하는 곳의 평온함이 국가기관에 의해서 불법수색이나 불법압수를 당하지 아니할 권리
주거의 불가침. 영장주의제도

사생활의 비밀과 자유(헌법 제17조)

자기 자신에 대한 외부로부터의 불가침을 전제로 사생활의 내용을 공개 당하지 아니할 권리 및 사생활의 자유로운 형성과 전개를 방해받지 아니할 권리
사생활 비밀의 불가침, 사생활 자유의 불가침, 자기정보관리통제권

통신의 자유(헌법 제18조)

개인이 그들의 의사나 정보를 자유롭게 전달, 교환하는 경우에 그 내용이 본인의 의사에 반하여 공개되지 않을 자유.
통신물에 대한 정보탐지를 금지하는 통신비밀의 불가침(**통신비밀보호법**)

재산권의 보장(헌법 제23조)

개인이 현재 누리고 있는 재산권을 개인의 기본권으로 보장한다는 의미. 개인이 재산권을 향유할 수 있는 법제도. 사유재산제도를 보장한다는 이중적인 의미.

사유재산권 보장. 구체적 재산권 보자(사용·수익·처분 권리보장) 소급입법에 의한 재산권 박탈 금지. 무체재산권 보장

정신적 자유권

양심의 자유 : 제한의 범위가 가장 좁은 절대적 자유권. 양심결정의 자유. 침묵의 자유. 양심실현의 자유

종교의 자유

언론·출판의 자유 : 의사표현의 자유. 알 권리. 언론기관의 자유.

집회·결사의 자유

학문의 자유

예술의 자유

사회권적 기본권

인간다운 생활을 할 권리

교육을 받을 권리

근로의 권리

근로3권 : 단결권, 단체교섭권, 단체행동권

환경권

혼인·가족·모성·보전에 대한 권리

청구권적 기본권

청원권 : 국가기관에 대하여 의견이나 희망을 진술할 권리. 반드시 문서로 제기. 국가는 청원 수리, 심사의 의무.

재판청구권 : 독립된 법원에 의하여 정당한 재판을 받을 권리

형사보상청구권 : 형사피의자, 형사피고인으로 구금되었던 자가 불기소/무죄 판결을 받은 경우 보상 청구권리

국가배상청구권 : 공무원의 직무상 불법행위로 피해를 입은 경우 국가 또는 공공단체에 대해 보상 청구권리

범죄피해자구조청구권 : 타인의 범죄행위로 피해를 입은 경우 국가에 대하여 구조를 청구할 수 있는 권리

정치적 기본권

선거권 : 선거인단의 구성원으로서 국민이 각종 공무원을 선출하는 권리

공무담임권 : 각종 선거직 공무원을 포함한 모든 국가기관의 공직에 취임할 수 있는 권리

피선거권

공직취임권(공무원 피임명권)

국민투표권 : 국가의 국가의사의 형성에 직접 참가할 수 있는 권리. 직접민주제의 한 형태.

국가 중요정책에 대한 국민투표 + 개헌안에 대한 국민투표

통치구조

통치의 원리

대의제의 원리(국민대표주의. 간접적으로 참여) + 권력분립의 원리(분리와 균형. 국가권력 남용 방지. 기본권 보장)

but 직접민주제적 요소가 있다! 국민투표제 실시. 국민발안제, 국민소환제는 채택하고 있지 않음..

대통령제 vs 의원내각제

대통령제 : 집행부와 입법부의 상호독립. 집행부의 일원성. 행정의 일원성. 권력분립

의원내각제 : 집행부와 입법부에 대한 정치적 책임. 행정의 이원성. 권력융합.

>>우리나라는 대통령제를 원칙. 의원내각제적 요소를 가미한 혼합형.(의원내각제적 요소가 있음 p.303)

국회

단원제 vs 양원제

단원제 : 신속. 비용절약. 정부와 충돌 시 해결 곤란

양원제 : 연방국가는 지방의 이익 옹호. 상원은 원로 구실. 처리지연, 경비과다. 책임소재 불분명

우리나라 국회의 헌법상 지위

국민의 대표기관, 유일한 입법기관, 국정의 통제기관, 예산·결산의 심의기관

국회의 구성

단원제

보통·평등·직접·비밀선거에 의해 선출된 의원과 비례대표제에 의한 간선의원으로 구성(임기 4년)

의원정수는 법률로 정하되, 200인 이상

국회의 회기

정기회 : 매년 1회(9월 1일) 개회. 회기는 100일을 초과하지 못함

임시회 : 대통령 또는 국회 재적의원의 4분의 1 이상의 요구. 회기는 30일을 초과하지 못함

운영원칙

의사공개의 원칙

회기계속의 원칙 : 한 회기 중에 토의하지 못한 안건은 폐기X, 다음 회기로 이어짐.(but, 국회 끝나면 폐기)

일사부재의의 원칙 : 회기 중 한 번 부결된 안건은 같은 회기 내에 재발의하거나 심의하지 못한다는 원칙

국회에서 정족수

의사정족수 : 국회 재적의원 5분의 1 이상의 출석으로 개의

의결정족수 : 일반의결정족수, 특별의결정족수

국회의 권한

입법, 국정통제, 재정, 헌법기관 구성에 대한 권한 有. 국회의 자율권

국회의원의 특권과 의무

불체포특권, 면책특권

겸직금지의무, 청렴의무, 국익우선의무, 지위 및 특권 남용 금지의무

대통령

대통령의 지위

행정부 수반으로서의 지위

국가원수로서의 지위

대통령의 선출

국민의 보통·평등·직접·비밀선거를 통해 다수표를 획득한 후보가 당선

40세 이상 출마가능. 5년 단임(중임금지). 국내거주 5년이상

대통령의 특권과 의무

내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상의 소추를 받지 아니함.

탄핵 결정에 의하지 아니하고는 공직으로부터 파면되지 아니함

헌법준수, 국가보위, 조국의 평화적 통일, 민족문화와 창달 등의 직무를 성실히 수행할 의무가 있음.
공·사의 직을 겸할 수 없음

대통령의 권한

1. 행정에 관한 권한
2. 입법에 관한 권한
3. 사법에 관한 권한
4. 헌법기관에 구성에 관한 권한
5. 비상적 권한

권한 행사방법

문서주의 부서제도 국무회의 심의 각종 자문기관이 자문
※부서제도※ : 공문서에 대해 국무총리 또는 관계 국무위원이 함께 서명하는 것

권한대행

국무총리 : 대통령이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 1차적으로 대행.
국무위원 : 2차적으로는 법률이 정한 국무위원의 순서에 따라 그 권한을 대행

행정부의 조직과 권한

국무총리

임명 : 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명
지위 : 대통령의 보좌기관, 대통령의 권한대행자. 행정부의 2인자. 국무회의 부의장. 중앙행정관청
겸직여부 : 국회의원 겸직가능(ex. 이낙연)
권한 : 국무위원 및 행정각부 장관의 임명제청권과 해임건의권.... p316

국무회의

구성 : 대통령 + 국무총리와 15~30인의 국무위원
지위 : 헌법상의 필수기관. 정책심의기관. 행정부의 최고정책심의기관

국무위원

임명 및 해임 : 국무총리의 제청으로 대통령이 임명. 국무총리, 국회의 건의에 의해 대통령이 해임
지위 : 국무회의의 구성원. 대통령의 보좌기관
권한 : 국무회의 의안 제출 및소집요구권, 국회에의 출석·발언권. 부서할 권한

행정각부의 장

대통령을 수반으로 하는 정부의 구성단위. 소관사무를 담당하는 중앙행정기관

임명 : 국무위원 중 국무총리의 제청에 의해 대통령이 임명
권한 : 소관사무를 결정·집행. 부령에 관한 권한. 정책입안권. 국무회의 참석권

★ 행정각부의 장은 모두 국무위원이지만, 국무위원이 모두 행정각부의 장인 것은 아니다★

감사원

구성 : 감사원장을 포함한 5~11인의 감사위원
임명 : 원장 - 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명
 위원 - 원장의 제청으로 대통령이 임명
임기 : 4년, 1차 중임 가능
지위 : 대통령에 소속되는 헌법기관. 법률로써 폐지할 수 없는 헌법상 필수기관
권한 : 국가의 세입·세출의 결산검사권 회계검사권 행정기관·공무원 감찰권 감사결과처리권

★참고 공무원 조직도

장,차관(임명직)
실장(1~2급)
국장(2~3급)
서기관(3~4급)
사무관(5급)
주무관(6~9급)

법원

헌법상 지위

1. 사법기관으로서의 지위
2. 독립적·중립적 기관으로서의 지위
3. 헌법수호기관으로서의 지위
4. 기본권 보장기관으로서의 지위

사법권의 독립

입법권이나 행정권으로부터 간섭을 받지 아니하고 독립하여 자유로운 재판을 할 수 있는 것
법원의 독립 : 권력분립의 원리. 법원의 조직, 운영, 기능 면에서 다른 국가권력기관으로부터 독립
법관의 독립 : 신분상 독립(임기보장·신분보장·정치적 중립성 보장)+직무상 독립(헌법, 법률 양심에 의해 재판)

헌법재판소

지위 : 정치적 사법기관으로서 사법적 방법에 의하여 헌법을 보장하는 기관

헌법재판을 통하여 기본권을 보장, 권력을 통제

구성 : 9인의 재판관 - 국회 3인, 대법원장 3인, 대통령 3인 -> 대통령이 임명

헌법재판소장 - 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명

임기 : 6년. 법률이 정하는 바에 의하여 연임가능

권한 : 1. 위헌법률심판권 2. 탄핵심판권 3. 위헌정당해산심판권 4. 권한쟁의심판권 5. 헌법소원심판권

선거관리위원회

지위 : 헌법상 필수기관, 합의체 기관

구성 : 9인의 위원 - 대통령 3인, 국회 선출 3인, 대법원장 3인 지명

위원장 - 위원 중에서 호선

임기 : 6년 연임가능

권한 : 1. 선거와 국민투표관리권 2. 정당사무처리권 3. 규칙제정권 4. 선거사범조사권 5. 재정신청권

민법

민법전의 구성

사법관계 : 재산관계 + 가족관계

제1편 : 민법 총칙 : 일반적인 규정

제2편 : 물권

제3편 : 채권

제4편 : 친족

제5편 : 상속

민법의 의의

형식적 의미 : 민법이라는 이름을 가진 법률을 의미함. “민법전”이라고도 함

실질적 의미 : 개인 상호 간의 **실체적 생활관계(재산관계와 가족관계)**를 규율한 사법. 사법의 일반법을 말함.

실체법으로써의 민법 : 권리와 의무의 존재 여부를 규율

민법의 법원(法源)

민법 제 1조 : 민사에 관하여 **법률**에 규정이 없으면 **관습법**에 의하고 관습법이 없으면 **조리**에 의한다.

-> 성문법주의를 취함 + 관습법과 조리의 법원성도 인정

민사 : 널리 사법관계를 의미

법률 : 민법전, 민사특별법, 조약, 명령, 규칙, 자치법규, 조례 등을 포함하는 개념(성문법을 통칭)

관습법 : 성문법이 없는 부분에 관하여서만 보충적으로 효력을 인정(보충적 효력설)

판례상 인정된 관습법 : 분묘기지권(무덤이 있는 땅을 계속 쓸 수 있음), 관습법상의 법정지상권(건물 주인이 바뀌어도 계속 쓸 수 있음), 동산의 양도담보(전당포), 미분리과실과 수목집단의 명인방법(과실 등에 붙이는 공고문) 등

근대 민법의 3대 원칙

소유권 절대의 원칙 : 사유재산권 존중. 주로 물권법 영역에서 인정

계약 자유의 원칙 : 사적 자치의 원칙, 법률행위 자유의 원칙. 주로 채권법 영역에서 적용

과실 책임의 원칙 : 자기 책임의 원칙. 고의 또는 과실로 위법하게 타인에게 손해를 야기하면 배상책임을 짐.

근대 민법의 3대 원칙의 수정

소유권 공공의 원칙 : 공공복리를 위해 소유권 등 재산권을 제약

계약 공정성의 원칙 : 신의성실의 원칙 및 권리남용금지의 원칙, 반사회질서 위반행위 금지, 임대차 강행규정, 유류 분제도 등 계약자유를 제한

무과실책임의 확대 : 당사자에게 고의 또는 과실이 없더라도 일정한 상황에서는 책임을 물음

법률관계의 의의

: **법에 의하여 규율되는 생활관계**

법은 사람의 모든 생활에 적용되는 것은 아님

강제력을 동원하여 일정한 결과를 실현하는 것이 적절한 때에만 적용

‘**호의관계**’와는 구별된다!

:법적인 의무가 없음에도 불구하고 **호의로 어떤 행위**를 해주기로 하는 생활관계

법적규율X, 법적제재X but, 일정한 손해가 발생한 경우 법적 책임을 물을 수 있으나 매우 불합리할 때만.

법률관계의 내용

권리(법에 의하여 보호) + **의무**(법에 의하여 구속)

✓ 민법은 권리 위주로 규율, 의무도 적지 않음.

권리의 행사

권리의 내용을 구체적으로 실현하는 과정

권리행사의 한계

1. 신의성실의 원칙(민법 제2조 제1항)

: 상대방의 믿음(신뢰)을 헛되이 하지 않도록 성의를 가지고 행동하는 것

* **사정변경의 원칙** : 객관적 사정의 현저한 변화로 계약을 변경하거나 **해제(쌍방)** 또는 **해지(일방)**할 수 있게 하는 원칙

* **금반언의 원칙(모순금지의 원칙)** : 권리행사가 종전의 행동과 모순되는 경우 권리행사가 허용되지 않는 원칙

* **실효의 원칙** : 권리행사의 기대가능성이 있었음에도 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 상대방으로서도 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것을 신뢰할만한 정당한 기대를 가지는 경우 신의성실의 원칙에 위반되어 허용되지 아니한다는 것

2. 권리남용금지의 원칙(민법 제2조 제2항)

: 외형상은 권리의 행사와 같이 보이지만 구체적·실질적으로는 권리의 사회성·공공성에 반하여 정당한 권리의 행사로써 볼 수 없는 경우 법률효과가 발생하지 않는다는 원칙

권리남용의 효과 : ★권리행사의 효과가 발생하지 않는 것이지, 권리자의 권리 자체가 소멸되는 것은 아님.

의무의 이행

: 의무자가 의무의 내용을 실현하는 행위를 하는 것

의무를 발생시킨 계약 또는 법률규정에 맞게 하여야 하며, 신의에 좇아 성실하게 하여야 함.

권리의 주체 ★헛갈림★ 잘 알아두기

* **권리능력** : 권리와 의무의 주체가 될 수 있는 지위 또는 자격. **자연인+법인**으로 법정·확일화

* **의사능력** : 자신의 행위의 의미나 결과를 정상적인 인식력과 예기력을 바탕으로 **합리적으로 판단할 수 있는** 정신적 능력 내지는 지능. 개별적으로 판단. 의사무능력자의 행위는 무효!

* **행위능력** : 의사능력을 가진 자가 독자적으로 유효하게 **법률행위**를 할 수 있는 능력. 행위능력이 없으면 **취소사유**
제한능력자 : 행위능력이 없는 자. 객관적으로 **법정·확일화** 되어있음.

* **책임능력** : 자기의 행위에 대한 책임을 인식할 수 있는 능력. 개별적 판단. 책임능력이 없으면 불법행위 성립X

자연인

권리능력은 **출생한 때(전부노출설)**부터 시작하여 **생존하는 동안** 계속됨

태아의 권리능력 : 태아는 출생 전이므로 민법상 사람이 아님. 권리능력을 가지지 못함.

>>but, 개별적 보호주의에 따라 태아의 권리능력을 인정

1. 불법행위에 기한 손해배상청구

2. 재산상속, 대습상속, 유증, 사인증여, 유류분 등의 경우에 있어서 **이미 출생한 것으로 봄**.

권리능력의 종기(끝) : 권리능력은 사망 시(심장박동정지설) 소멸함.

사망 사실 또는 사망 시기의 증명 곤란에 대비한 제오

1. **동시사망의 추정**(같은 사고나 사건으로 사망했을 때 동시에 사망한걸로 추정)

2. **인정사망**(사망의 확증이 없지만 사망이 확실할 때)

3. **실종선고**

제한능력자 : 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 없는 자(행위능력이 제한됨).

미성년자 : 19세 미만의 자. 단독 법률행위 불가, 법정대리인의 동의 必 동의 못한 행위는 **취소** 가능.

>>취소 : 유효하게 성립한 법률행위의 효력을 소급하여 무효로 돌리는 것

피성년후견인 : 질병·장애·노령·그 밖의 사유로 인한 **정신적 제약**으로 사무를 처리할 능력이 **지속적으로 결여된 사람**. 가정법원으로부터 **성년후견개시의 심판**을 받은 자.

성년후견인의 동의를 얻지 않고(자체적으로) 한 행위뿐만 아니라 **동의를 얻고서 한 행위도 취소 가능**

>> **피성년후견인 행위능력이 없음!**

피한정후견인 : 질병·장애·노령·그 밖의 사유로 인한 **정신적 제약**으로 사무를 처리할 능력이 **부족한 사람**. 가정법원으로부터 **한정후견개시의 심판**을 받은 자.

피한정후견인은 원칙적으로 행위능력을 갖지만, 한정후견인의 동의를 받도록 정한 법률행위를 **동의없이** 한 경우 취소할 수 있음.

제한능력자의 상대방 보호 제도

: 제한능력자의 법률행위는 취소할 수 있고, 그 취소권은 제한능력자 쪽에서만 가지고 있으므로 상대방을 보호할 필요성이 있음.

상대방의 확답을 촉구할 권리 : 제한능력자 측의 취소할 수 있는 행위에 대하여 주인 여부에 대한 확답 요구

※주인 : “유효한 계약으로 하자”고 확정하는 의사표시

철회권 : 계약을 체결한 경우 제한능력자 측이 주인이 있기 전, 상대방은 철회할 수 있음.

거절권 : (제한능력자가) 단독행위를 한 경우 제한능력자의 주인이 있기 전에 상대방이 거절할 수 있음.

취소권의 배제 : 제한능력자가 속임수를 쓴 경우 제한능력자는 취소를 요구할 수 없음

법인

: 자연인이 아니면서 법에 의해 법인격(권리능력)이 부여된 것.

구분	사단법인	재단법인
의의	일정한 목적을 가진 사람의 단체	일정한 목적을 위해 출연한 재산 을 구성요소로 함
설립행위	정관작성	재산출연, 정관작성
정관변경	총회 결의(총 인원 3분의 2 이상의 동의) + 주무관청허가	변경방법을 정관에서 정하고 있을 때, 목적달성 불가 시 (주무관청허가)
기관구성	✓이사, 감사, 사원총회 ✓의사결정기관 : 사원총회	✓사원, 사원총회 없음 ✓의사결정기관 : 정관에 따름
해산	임의해산	임의해산 없음
공통점	설립허가절차, 등기, 주무관청의 검사·감독, 해산과 청산절차	

정관 : 회사의 헌법. 가장 기본적 규칙

권리능력 : 법률·성질·목적에 의해 제한 가능.

정관에서 정한 ‘목적범위 내’에서만 권리능력을 가짐.(목적에 의한 제한)

행위능력 : 권리능력의 범위와 일치

법인의 불법행위

1. 대표기관의 행위일 것
2. 대표기관이 직무(일 하다가 저지른 잘못)에 관하여 타인에게 손해를 가했을 것

성립하는 경우

- **법인은 피해자에 대해 손해배상책임**
- 이사나 그 밖의 대표기관도 배상책임 부담

성립하지 않는 경우

- **대표기관만 불법행위(제750조)에 의하여 책임**
- 그 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원, 이사와 그 밖의 대표기관은 연대하여 배상책임

이사 : 법인을 설립하기 위해 등기된 사람
대표기관(이사 등)은 사람을 말함.

권리의 객체

: 권리의 효력이 미치는 대상을 말하며, 권리의 목적·내용·종류에 따라 다름.

물건의 정의

물건 : 유체물과 전기 기타 관리할 수 있는 자연력

1. 유체물만 있는 것이 아니고 무체물이라도 전기와 같은 관리 가능한 자연력은 물건.
관리 가능한 == 배타적 지배가 가능
2. 사람의 신체나 그 일부는 물건이 아님
3. 물건은 하나의 독립된 존재이어야 함(일물일권주의)

종류

부동산과 동산 : 부동산(토지 및 정착물. 건물, 수목의 집단, 미분리의 과실, 농작물)

동산 : 부동산 이외

주물과 종물 : 자기 소유인 다른 물건에 부속하게 한 경우, 그 물건은 주물. 부속시킨 다른 물건은 종물

원물과 과실 : 물건으로부터 생기는 경제적 수익이 과실. 과실을 생기게 하는 물건을 원물.

민법총칙

권리의 변동

: 법률관계의 발생·변경·소멸

법률요건 : 법률관계 변동의 원인이 되는 것

법률효과 : 그 결과로서 생기는 법률관계(권리)의 변동

권리의 발생(취득) : 원시취득(절대적 발생; 원래부터 발생), 승계취득(상대적 발생; 받거나 삼)

권리의 소멸(상실) : 절대적 소멸(권리 그 자체의 소멸), 상대적 소멸(권리의 주체 변경)

권리의 변경 : 권리가 동일성을 그대로 유지하면서 주체·내용 또는 작용(효력)에 있어서 변화가 있는 것

권리변동의 원인

1. 법률요건

- 1) 의사표시를 필수불가결한 요건으로 하는 법률행위
- 2) 법률행위 이외의 그 밖의 행위로서 민법이 권리변동의 효과를 발생시키는 것으로 정한 법률의 규정

2. 법률사실

법률요건을 구성하는 개개의 사실. 단독 또는 다른 법률사실들과 합쳐져 법률요건을 이루게 됨

- * 의사표시
- * 준법률행위(의사의 통지, 관념의 통지, 감정의 표시, 사실행위)
- * 사건

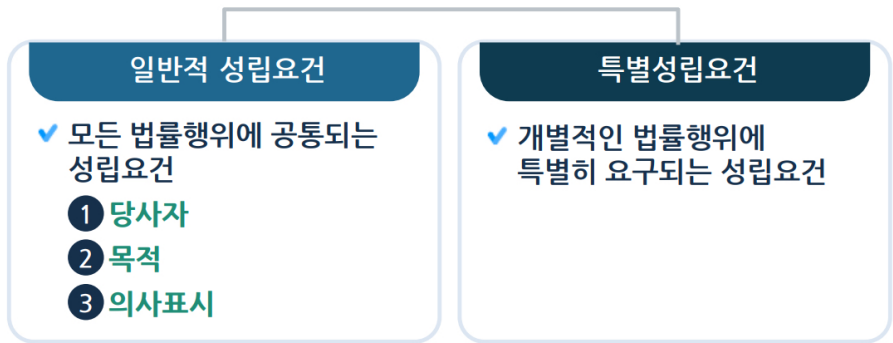
법률행위의 의의 및 성질

의의 : 일정한 법률효과를 발생할 목적으로 하여, 하나 또는 수 개의 의사표시를 불가결의 요소(법률사실)로 하는
법률요건 성질

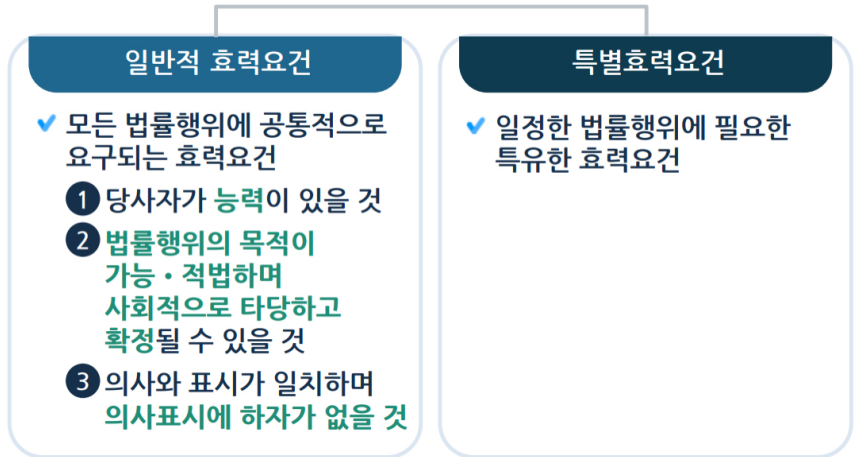
성질 :

1. 사법상의 법률요건
2. 추상화개념
3. 의사표시는 법률행위의 본질적 요소
4. 의사표시의 내용에 따른 법률효과 발생

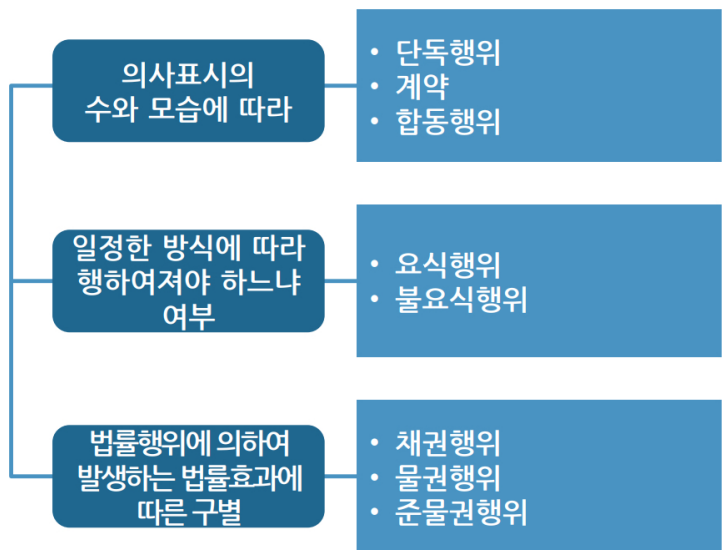
성립요건 : 법률행위의 존재를 위해 필요한 최소한의 형식적·외형적 요건



효력(유효)요건 : 이미 성립한 법률행위가 효력을 발생하는 데 필요한 요건



법률행위의 종류



단독행위 : 하나의 의사표시에 의하여 성립하는 법률행위. 상대방이 있는 단독행위, 없는 단독행위가 있음. (일방)

계약 : 둘 이상의 서로 대립하는 의사표시의 일치에 의하여 성립하는 법률행위 (쌍방)

합동행위 : 평행적·구심적으로 방향을 같이하는 둘 이상의 의사표시의 일치로 성립하는 법률행위

요식행위 : 일정한 방식에 따라서 하여야만 효력이 인정되는 법률행위

불요식행위 : 방식에 구속되지 않고 자유롭게 행하여질 수 있는 법률행위

채권행위 : 채권을 발생시키는 행위.

★채권자는 채무자에 대하여 일정한 행위(급부)를 청구할 수 있는 권리를 가질 뿐, 권리가 직접 변동되지는 않음.★

채무자의 이행의 문제가 남게 됨.

- 물권행위 :** 물권의 변동을 목적으로 하는 의사표시를 요소로 하여 성립하는 법률행위
 직접 물권을 변동시키고 이행의 문제를 남기지 않음
 소유권 이전행위, 저당권 설정행위 등
- 준물권행위 :** 물권 이외의 권리를 종국적으로 변동시키고 이행이라는 문제를 남기지 않는 법률행위
 채권양도, 지식재산권 양도 등

무효	처음부터 법률상 효력이 없는 행위로 간주됨
취소	일단 유효하게 성립했지만, 나중에 소급하여 무효로 돌릴 수 있는 행위
해제	유효하게 성립한 계약을, 소급적으로 없던 일로 만드는 것 (주로 쌍무계약)
해지	유효한 계약을, 앞으로의 효력만 끊는 것 (주로 계속적 계약)

법률행위의 목적(내용)

- 확정성 :** 법률행위가 유효하기 위하여는 법률행위의 목적이 실현될 시점까지 확정되어 있거나 적어도 확정가능 하여야 함. **확정할 수 없으면 무효가 됨.**
- (실현) 가능성 :** 목적의 실현의 불가능한 법률행위는 무효. 실현 가능 여부에 대한 판단은 법률행위 성립 시를 기준.
- 적법성 :** 강행법규에 위반하지 않을 것.
 강행법규 : 법령 중 선량한 풍속 기타 사회질서과 관계있는 규정으로서 당사자의 의사에 의하여 적용 배제 불가.
- 사회적 타당성 :** 강행법규에 위반하지 않더라도 “선량한 풍속 기타 사회질서”에 위반하는 경우 그 법률행위는 무효
 ->반사회질서의 법률행위, 불공정한 법률행위

흠 있는 의사표시

- 진의 아닌 의사표시(비진의표시)**
 표의자가 진의 아님을 알고 한 것이라도 표시된 대로 효력이 있음. but, 상대방이 진의 아님을 알았거나 이를 알 수 있었을 경우에는 무효.
 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못함(몰랐던 제3자의에게는 무효가 아님. 제3자 보호)
- 통정한 허위의 의사표시(통정허위표시)**
 상대방과 통정(서로 짜고)하는 의사표시는 무효로 함.
 의사표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못함.
- 착오로 인한 의사표시**
 법률행위의 내용의 중요 부분에 착오가 있고, 표의자에게 중대한 과실이 없는 경우 취소할 수 있음.
 의사표시의 취소는 선의의 제3자에게 대항하지 못함.
- 사기·강박에 의한 의사표시**
 상대방이 사기·강박한 경우 > 언제든지 취소 가능
 제3자가 사기·강박한 경우 > 상대방이 알았거나 알 수 있었을 경우에만 취소 가능

의사표시의 효력 발생

- 도달주의 원칙 :** 상대방 있는 의사표시는 그 통지가 상대방에게 도달한 때에 효력이 생김
- 도달주의의 예외(발신주의) :** 일정한 경우에 그 통지를 발송한 때에 효력이 생김
- 표의자가 그 통지를 발한 후 사망하거나 행위능력을 상실하여도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 않음.

의사표시의 공시송달 : 표의자가 과실 없이 의사표시의 상대방을 알지 못하거나, 상대방의 소재를 알지 못하는 경우

법률행위의 대리

타인이 본인의 이름으로 법률행위(의사표시)를 하거나 또는 의사표시를 받음으로써 그 법률효과가 직접 본인에게 생기는 제도

본인 - 대리인 : 대리권

나와 변호인

대리인 - 상대방 : 대리행위

상대방 - 본인 : 법률효과

대리가 인정되는 범위

: 대리는 원칙적으로 의사표시 또는 의사표시를 요소로 하는 법률행위에 한하여 인정

대리와 친하지 않은 법률행위(대리가 안됨) : 본인의 의사결정이 절대적으로 필요한 법률행위적 의사표시
가족법상의 행위인 혼인, 유언 등

대리가 인정되지 않는 행위 : 준법률행위(의사나 관념의 통지는 예외적으로 가능), 사실행위, 불법행위

대리의 종류

임의대리와 법정대리

능동대리와 수동대리

구분	법정대리권	임의대리권
발생원인	✓ 법률의 규정 ✓ 지정권자의 지정행위 ✓ 법원의 선임행위	✓ 본인의 수권행위
소멸	✓ 본인 또는 대리인의 사망, 대리인의 성년후견 개시 또는 파산 ✓ 원인이 된 법률관계의 종료 ✓ 수권행위의 철회	✓ 법률의 규정(법원에 의한 대리인의 개임 · 대리권 상실선고 등)

※수권 : 권한을 주다

※수인 : 受任. 권한을 받은 사람. 대리인.

대리권의 제한

자기계약·쌍방대리의 금지

자기계약(본인-대리인 사이에 계약)

쌍방대리(대리인이 본인과 제3자 사이에서 대리)

공동대리의 경우 -

원칙 : 대리인이 수인(여러명)인 경우라도 각자대리가 원칙

예외 : 법률 또는 수권행위에 의해 공동대리로 정해진 경우에만 대리인이 공동으로 법률행위 가능.

현명주의

: 대리인이 대리행위를 함에 있어서 “본인을 위함 것임을 표시”하고 의사표시를 하여야 함.

밝히지(현명) 않으면, 그 의사표시는 대리인 자신을 위한 것으로 봄.

but, 상대방이 대리인으로 한 것임을 알 수 있었을 때는 유효한 대리행위가 됨.

대리인의 능력

★대리인은 의사능력만 있으면 족하고, 행위능력자임을 요하지 않음.

복대리

복대리인에 대한 대리 : 대리인이 그의 권한 내의 행위를 하기 위하여 대리인 자신의 이름으로 선임한 본인의 대리인 >> 복대리인을 선임하여도 대리인의 대리권을 소멸하지 않는다!

무권대리

: 대리권 없이 행한 대리행위 또는 대리권의 범위를 넘어 한 대리행위

표현대리 : 대리인에게 대리권이 없음에도 불구하고, 마치 그것이 있는 것과 같은 외관이 있고, 그러한 외관의 발생에 대하여 본인이 어느정도 책임이 있는 경우, 그 무권대리 행위에 대하여 **본인에게 책임을 지게** 하는 제도

- * 대리권수여의 표시에 의한 표현대리
- * 권한을 넘은 표현대리
- * 대리권 소멸 후의 표현대리

협의의 무권대리 : 표현대리의 요건을 갖추지 않은 경우.

본인이 추인하지 않는 한 **무권대리인** 자신의 책임이 됨.

법률행위의 무효와 취소

무효

: 법률행위가 성립한 당시부터 법률상 당연히 그 효력이 발생하지 않는 것이 확정되어 있는 것.

효과 : 법률행위가 무효(절대·당연무효)임. 법률행위에 의하여 의욕된(원했던) 법률효과는 발생하지 아니함.

일부무효

: 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 원칙적으로 그 전부를 무효로 함.

BUT, 그 무효 부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 않음.

취소

: 일단 유효하게 성립한 법률행위의 효력을 제한능력, 의사표시의 착오·사기나 강박을 이유로 특정인(취소권자)의 의사표시에 의하여 그 법률행위를 한 때에 소급하여 무효로 하는 것

효과 : 취소할 수 있는 법률행위라 할지라도 취소권자의 취소가 있을 때까지 유효. 취소가 있으면 처음부터, 즉 소급하여 무효가 됨.

취소된 법률행위에 기하여 미이행 부분은 소멸. 기이행 부분은 부당이득으로 반환하여야 함.

법률행위의 부관

: 법률행위의 효과를 제한하기 위하여 법률행위의 내용으로 덧붙여지는 약관(사적 자치적인 결정)

조건 : 법률행위 효력의 발생 또는 소멸을 장래의 불확실한 사실의 성취(발생) 여부에 따르게 하는 법률행위의 부관

정지조건 : 법률행위의 효력의 발생을 장래의 불확실한 사실에 따르게 하는 조건

ex) 결혼하면 아파트 한 채를 사주겠다. > 하면 사주겠다.

해지조건 : 법률행위의 효력의 소멸을 장래의 불확실한 사실에 따르게 하는 조건

ex) 취직할 때까지 생활비를 대 주겠다. > 하면 안 대주겠다.

기한 : 법률행위 효력의 발생·소멸 또는 채무이행의 시기를 장래 발생할 것이 확실한 사실에 따르게 하는 법률행위의 부관

기한이 되는 사실이 장래의 것이라는 점에서 조건과 동일하지만, 발생이 확정되어 있다는 점이 다르다.

기한의 이익 : 기한이 존재함으로써, 즉 기한이 되지 않음으로써 당사자가 받는 이익

기한

기간과 소멸시효

기간 : 어느 시점에서 어느 시점까지 계속된 시간의 구분

!= 기일 : 시간의 경과에 있어서 어느 특정의 시점을 가리킴.

기간의 계산방법

자연적 계산방법 : 시·분·초를 정한 때에는 **즉시**로부터 기산 (※기산 : 계산을 시작하다)

역법적 계산방법 :

- 1) 일·주·년·월으로 정한 때에는 원칙적으로 **첫날을 넣지 않음**.(초일 불산입의 원칙)
(예외 : 연령의 계산, 오전 0시부터 기산하는 경우)
- 2) 일·주·월·년으로 정한 때에는 **기간 말일의 종료(그날 24시)**로 만료

기간의 역산 : 기간의 계산방법은 기간을 과거로 소급하여(거꾸로)계산하는 기간의 경우에도 유추적용됨.

소멸시효

: 권리자가 일정한 기간 동안 권리를 행사하지 않는 상태가 계속된 경우에 그의 권리를 소멸시키는 것

시효 : 일정한 사실상태가 오랫동안 계속된 경우에/ 그 상태가 진실한 권리관계에 합치하는가를 묻지 않고 서도/ 그 사실상태를 그대로 권리관계로서 인정하려는 제도.

>> 시간이 지내면 어떤 권리가 생기거나 없어지는 것

소멸시효의 요건

- * 권리가 소멸시효에 걸리는 것이어야 함.
- * 권리자가 법률상 그의 권리를 행사할 수 있음에도 불구하고 행사하지 않아야 함(권리의 불행사)
- * 권리의 불행사의 상태가 일정한 기간(소멸시효기간)동안 계속되어야 함.

소멸시효의 중단

- * 소멸시효 완성에 필요한 권리의 불행사가 일정한 사유(청구 압류·가압류·가처분, 승인)에 의한 경우에는 중단.
- >> 이미 경과한 시간이 無로 돌아감. **완전 리셋**

소멸시효의 정지

- * 시효가 거의 완성될 무렵에 권리자가 중단행위를 할 수 없거나 극히 곤란한 사정이 있는 경우에 시효의 완성을 일정한 기간동안 유예하는 것
- * 정지사유가 소멸한 뒤, 일정한 유예기간이 경과하면 시효가 완성됨.

>> 이미 경과한 시간은 그대로 유지. **잠깐 일시정지**

민법 - 재산법

물권법

: 물건 기타 객체에 대한 지배관계, 즉 물권관계를 규율하는 일반사법
소유권을 중심으로 하는 재산법.

물권

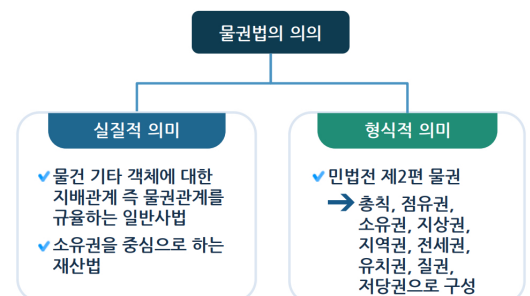
: 특정한 독립한 물건을 직접 지배하여 이익을 얻는 배타적·독점적 권리

내용면 - 재산권

효력면 - 지배권

의무자의 범위 - 절대권

(모든 사람을 대상으로 이 물건 내거야! 라고 할 수 있음)



물권의 본질

원칙적으로 특정되어 있고 독립한 물건이어야 함.

일물일권주의 : 하나의 물건 위에는 내용상 병존(양립)할 수 없는 물권은 하나만 성립할 수 있다.일무

객체에 대한 직접적인 지배권 : 권리의 실현을 위해 타인의 행위를 기다릴 필요가 없음

객체에 대한 배타적(독점적) 지배권 : 서로 양립할 수 없는 내용의 권리가 둘 이상 성립할 수 없는 성질.

절대권 : 특정한 상대방이 없고 모든 자에 대하여 효력이 인정.

물권법정주의

물권의 종류와 내용은 민법 기타 법률 또는 관습법에 의하는 것에 한하여 인정됨.

당사자가 그 밖의 종류와 내용을 자유롭게 창설하지 못한다는 원칙.

강행규정 : 물권법정주의에 반하는 법률행위는 무효

민법상의 물권 : 점유권, 소유권, 지상권, 지역권, 전세권, 유치권, 질권, 저당권

특별법상의 물권 : 공장저당권, 자동차저당권, 가등기담보권 등...

관습법상의 물권 : 판례에 의해 확인. 분묘기지권, 관습법상 법정지상권

물권과 채권의 차이

구분	대상	성질	공시	내용
물권	물건	✓절대성 ✓직접성 ✓지배권	필요	법률·관습법에 의하여 결정됨
채권	사람의 행위	✓상대성 ✓간접성 ✓청구권	불필요	당사자의 자유로운 의사에 의하여 결정할 수 있음

물권의 효력

우선적 효력 : 권리가 다른 권리에 우선하는 효력을 가짐.

물권 상호간의 우선적 효력 : 시간상 먼저 생긴 물권, 제한물권(지상권, 저당권). 이 둘이 우선함

물권 vs 채권간 효력 : 원칙적으로 시간불문 물권이 우선

물권적 청구권 : 실현이 방해받고 있거나, 염려가 있을 경우 방해자에 대하여 방해의 제거 또는 예방에 필요한 일정한 행위를 청구할 수 있는 권리

물권적 반환청구권

물권적 방해제거청구권

물권적 방해예방 청구권

물권의 변동

의의 : 물권의 발생, 변경, 소멸

물권의 주체를 중심으로 하여 보면, 물권의 취득·상실·변경, 즉 득실변경이 됨. -> 부동산/동산의 득실변경

공시제도의 필요성 : 외부에서 물권의 존재 및 변동을 쉽게 인식할 수 있도록 공시방법(공시의 원칙)이 요구됨.

그러한 공시방법을 신뢰한 자를 보호하는 것(공신의 원칙)도 필요.

공시의 원칙 : 물권의 변동이나 내용을 외부에 표시해야 함. 부동산-부동산등기, 동산-점유, 인도

공신의 원칙 : 공시방법을 신뢰하고 거래한 경우 공시방법을 신뢰하여 거래를 한 자는 보호되어야 함.

동산의 선의취득제도

부동산물권의 변동

물권행위 + (부동산)등기

형식적 유효요건 : 부동산등기법에 따라 등기부에 기재하는 것.

실체적 유효요건 : 물권변동과 등기가 합치

상속, 공용징수, 판결, 경매 기타 법률의 규정에 의한 경우
 >> 등기하지 않아도 물권변동이 발생
 >> 취득한 부동산을 처분하기 위해서는 등기를 요함.

권리자로부터의 취득(민법 제188조 제1항)
 물권행위 + 인도

무권리자로부터의 취득 - 선의취득(민법 제249조)
 동산의 점유에 공신력을 인정하여 거래의 안전을 보호.
 일정한 요건하에 무권리자로부터도 **동산의 소유권을 취득**

법률행위에 의하지 않은 동산물권의 변동
 동산의 취득시효, 선점, 유실물습득, 매장물발견, 동산 간의 부합, 혼화, 가공 등...

민법이 인정하는 물권의 종류

점유권				
본권	소유권(완전물권)			
	제한물권	용익물권	지상권, 지역권, 전세권	
		담보물권	법정담보물권	유치권
			약정담보물권	질권, 저당권

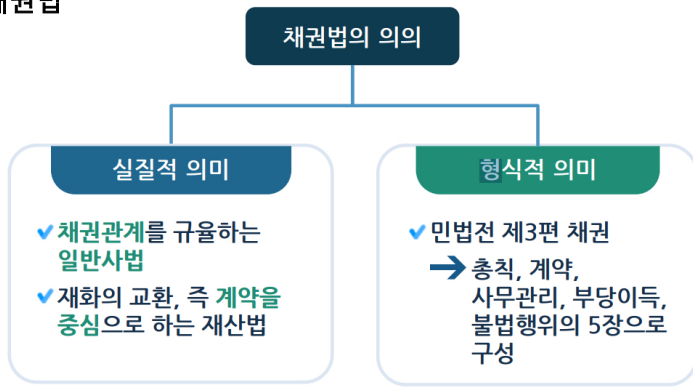
점유권 : 사실상 지배하고 있는 경우. (지배할 수 있는 권리가 있는지는 묻지 않음)
 본권 : 물건을 지배할 수 있는 권리 (사실상 지배하고 있는지는 묻지 않음.)

소유권 : 물건을 전면적으로 지배할 수 있는 권리(사용·수익, 처분)
 제한물권 : 제한된 방법으로 특정 목적을 위해 물건의 가치를 일부만 지배할 수 있는 권리

용익물권 : 물건이 가지는 사용가치의 지배를 목적으로 하는 물건. -> 지상권, 지역권 ,전세권
 지상권 : 타인의 토지에서 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지의 상하를 배타적으로 사
 용할 수 있는 물권
 지역권 : 일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기의 토지의 편익에 이용하는 물권
 전세권 : 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 사용·수익하고, 전세권이 소멸되면 전세금의 우선변
 제를 받을 수 있는 물권

담보물권 : 물건이 가지는 교환가치의 지배를 목적으로 하는 물건 -> 유치권, 질권, 저당권
 유치권 : 타인의 물건 또는 유가증권을 점유한 자가 **채권의 변제를 받을 때까지** 물건 또는 유가증권을 유치
 (가지고 있을 수 있는) 물권
 질권 : **채권자**가 담보로서 채무자/제3자의 **동산 또는 재산권을 유치**, 채무에 변제가 없을 때 목적물로부터
 우선변제를 받는 물권
 저당권 : **채무자/제3자**가 담보로 제공한 **부동산** 기타의 목적물을 인도받지 않고 **지배**하다가 채무의 변제가
 없는 경우에 그 목적물로부터 우선변제를 받는 물권

채권법



채권법의 특징

임의규정성 : 계약법에 있어서 사적 자치가 널리 인정

국제성, 보편성

동적 : 물건·노무의 이동 등 현재 상태의 변경을 규율

신의칙의 지배 : 채권법이 규율하는 채권은 당사자 이행을 청구할 수 있는 권리이므로 채권의 당사자 사이에서 신뢰가 매우 중요

채권

: 특정인(채권자)이 다른 특정인(채무자)에게 일정한 행위(급부)를 요구할 수 있는 권리

내용면 - 재산권 효력면 - 청구권 의무자의 범위 - 상대권

채권의 본질

청구권 : 채무자에게 일정한 행위를 청구할 수 있는 권리. 채무자의 행위가 있어야 실현.

상대권 : 특정인이 채무자에 대해서만 주장할 수 있음

평등성 : 배타성이 없음. 채권은 실질적으로 양립할 수 없는 것이라도 동시에 둘 이상 존재할 수 있으며, 채권의 효력에 있어서도 차이가 없음 (채권자 평등의 원칙)

채권관계

민법은 채권에 관하여만 규정

>> 채권으로만 파악되지 않는 의무도 존재.

2인 이상의 특정인 사이에 채권·채무가 존재하는 법률관계

>> 채권자와 채무자라는 특정한 사이의 법률관계(특별구속관계)

기본적인 채권·채무만이 존재하는 것이 아니고, 그 밖의 여러가지 권리(항변권, 해제권, 해지권)와 의무(통지의무, 배려의무)도 포괄함.

채권의 목적

의의 : 채무자가 하여야 하는 행위(급부)

채권은 채권자가 채무자에게 일정한 행위를 청구하는 것을 내용으로 하는 권리

요건 : 법률의 규정에 의하여 채권이 발생한 경우

법률행위에 의하여 채권이 발생한 경우

채권의 발생원인

민법 제3편 채권 - 계약, 사무관리, 부당이득, 불법행위에 관하여 개별적인 사항을 규정

법률행위에 의한 채권의 발생

계약 : 당사자 사이의 의사표시의 합치(청약과 승낙)으로서 성립.

민법에서는 15가지의 전형예약을 규정.

법률행위가 아닌 것에 의한 채권의 발생

사무관리 : 법률상의 의무 없는 타인의 사무를 처리하는 행위 (비오는 날 창문 닫아주기)

부당이득 : 법률상 원인 없는 이득 -> 부당이득 반환청구권

불법행위 : 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가하는 행위 -> 피해자의 손해배상청구권

계약

개념 : 서로 대립하는 두 개 이상의 의사표시의 합치에 의하여 성립하는 법률행위

성립 : **청약 + 승낙**

청약 : 그에 대응하는 승낙과 결합하여 계약을 성립시킬 것을 목적으로 하는 일방적·확정적 의사표시

!= **청약의 유인** : 상대방에게 청약을 하게 하려는 행위(구인공고, 카탈로그 배부, 아파트 분양광고...)

승낙 : 청약에 응하여 계약을 성립시킬 것을 목적으로 청약자에 대하여 하는 의사표시

계약의 해제·해지

해제 : 유효하게 성립하고 있는 계약의 효력을 당사자 일방의 의사표시에 의하여 **처음부터 없었던 것과 같은 상태**로 되돌아가게 하는 것

약정해제권 : 당사자 사이의 계약에 의하여 발생하는 해제권

법정해제권 : 법률의 규정에 의하여 발생하는 해제권

해제의 효과

1. 계약의 **소급적 실효**
2. **원상회복의무**와 동시이행
3. 해제와 (채무불이행으로 인한) **손해배상청구**

해지 : **계속적 계약관계**의 경우 일방적 의사표시로 그 효력을 **장래에 향하여 소멸**시키는 것

계속적 계약관계 : 급부가 일정한 시점에 행하여지는 것이 아니라 일정한 기간동안 계속해서 행하여지는 채권관계(소비대차, 임대차, 고용, 위임 등)

해지의 효과

1. **장래효**(해지가 있기 전에 이미 성립한 채무는 소멸X, 존속하므로 이행하여야 함)
2. **계약관계의 청산의무**
3. **손해배상청구**

채무불이행

: 채무자에게 책임 있는 사유로 **채무의 내용에 좇은 이행이 이루어지지 않고 있는 상태**

요건

1. 객관적 요건

이행지체 : 이행이 가능함에도 불구하고 이행기에 이행하지 않고 있을 것

- 본래 급부청구 or 강제이행+지연배상, 전보배상, 일정 요건 下 계약해제+손해배상청구

이행불능 : 이행기에 이행이 불가능할 것

- 전보배상, 최고 없이 계약해제, 대상청구권

불완전이행 : 이행은 있었으나 채무의 내용에 좇은 이행이 아닐 것

- 완전이행청구, 손해배상청구...

2. 주관적 요건

채무자의 귀책사유(**고의·과실**)

3. 위법성

소극적 요건으로서 **위법성 조각사유가 없으면 위법하다고 평가**

4. 채무자의 책임능력

5. 증명책임의 문제

채권자의 증명책임 : 채무의 존재 사실과 채무불이행의 객관적 요건

채무자의 증명책임 : 채무불이행의 주관적 요건

불법행위

: 고의 또는 과실로 위법하게 타인에게 손해를 가하는 행위. 가해자는 피해자에 대하여 손해배상책임을 부담

일반 불법행위

특수 불법행위 : 일반 불법행위의 요건 외에 추가적인 요건이 더 갖추어진 경우에 인정

성립요건 of 일반 불법행위 :

가해자의 고의·과실에 의한 행위

가해자의 책임능력

가해자의 위법성

가해행위에 의한 손해발생 : **현실적 손해**의 발생 + 가해행위-손해 발생의 **인과관계** 존재

손해배상

민법은 손해배상에 관하여 그 범위 및 방법, 배상액의 예정, 과실상계, 손해배상자의 대위 등을 규정함.

채무불이행으로 인한 손해배상에 관한 대부분의 규정은 **불법행위로 인한 손해배상**에도 준용(준하여 적용)

-> 불법행위에도 동일하게 적용.

손해

: **일정한 원인**에 의하여 피해자가 입는 불이익

종류

재산적 손해 vs 비재산적 손해 : 침해행위로서 발생하는 불이익이 재산적인가? 비재산적인가?

비재산적 손해는 aka **정신적 손해** - 위자료

이행이익의 손해와 신뢰이익의 손해

이행이익(계약이 이행되지 않음으로서 생긴 손해)

신뢰이익(법률행위의 유효를 믿음으로써 생긴 손해)

직접적 손해 vs 간접적 손해

직접적 손해 : 침해된 법익 자체에 대한 손해

간접적 손해 : 법익 침해의 결과로 피해자의 다른 법익에 발생한 결과적 손해

범위

통상손해 (민법 제393조 제1항)

채무불이행으로 인한 손해배상은 **통상의 손해**를 그 한도로 한다.

상당인과관계설(통설·판례)에 따라 손해배상의 범위를 제한. **객관적**으로 선행사실로부터 초래되는 후행사실이 있을 때.

>>예견할 수 있는 범위 내의 손해

특별손해 (민법 제393조 제2항)

특별한 사정으로 인한 손해는 **채무자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때**에 한하여 배상책임이 있다.

당사자들의 개별적·구체적 사정에 따른 손해.

채무자의 예견가능성이 기준. >> 채무자가 알 수 있었던 경우에 한하여 배상을 청구할 수 있음.

방법

원칙 : 금전배상주의

민법은 손해배상방법으로 원상회복주의가 아니라 금전배상주의를 취하고 있음.

법원이 직권으로 원상회복을 명하는 것은 위법(by 판례)

예외

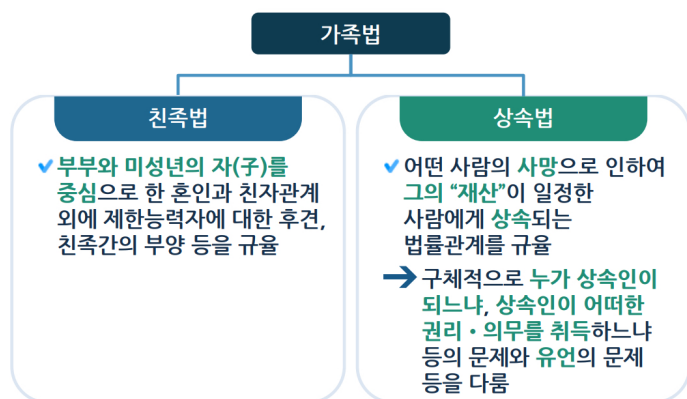
당사자의 합의가 있으면 합의한 방법대로 손해배상 가능.

명예훼손의 경우 : 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 적당한 처분을 명할 수 있음

민법 - 친족법, 상속법

가족법

: 민법 중 남녀의 성적 결합과 부모·자식의 관계 등의 가족관계와 유언 및 상속의 관계를 규율하는 법



특질 : 비타산성·비합리성

강행법규성

보수성

친족

배우자, 혈족 및 인척.

배우자

: 혼인으로 결합된 남녀. 혼인을 하면 서로 배우자가 됨.

법률상의 부부를 의미. 사실혼 부부는 배우자가 아님.

배우자의 관계는 혼인에 의하여 발생하고, 당사자 일방의 사망, 혼인의 무효·취소 또는 이혼으로 소멸

혈족(血族)



직계존속 : 부모님, 조부모님...

직계비속 : 자식....

인척

혼인으로 성립하는 친족

혈족의 배우자, 배우자의 혈족, 배우자의 혈족의 배우자

인척관계는 혼인의 성립으로 발생하며, 혼인의 무효·취소, 이혼 또는 부부 일방의 사망 후 생존배우자의 재혼으로 종료됨

친족의 범위

8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자

친족관계로 인한 법률상의 효력은 민법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 이 범위에 미치게 됨

가족의 범위

배우자, 직계혈족 및 형제자매

직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매(생계를 같이 하는 경우에 한함)

혼인

: 1남 1녀가 평생 부부로서의 생활공동체를 형성하기로 하는 친족법상의 합의

성립요건

1. 당사자의 혼인의 합의 : 혼인은 계약에 해당하므로, 당사자의 의사표시의 일치(합의)가 있어야 함.
2. 혼인신고 : 신고하여야 함. -> 법률혼주의(신고주의)

장애사유

1. 혼인적령의 미달 : 남녀모두 18세미만
2. 부모 등의 동의를 결여 : 미성년자와 피성년후견인에 한함.
3. 근친혼 : 8촌 이내의 혈족, 6촌이내의 배우자... 등등
4. 중혼 : 배우자가 있는 자

혼인의 무효

1. 당사자 간의 혼인의 합의가 없는 때
2. 당사자 사이에 근친 관계가 있는 때
3. 당사자 간에 직계인척관계가 있거나 있었던 때
4. 당사자 간에 양부모계의 직계혈족관계가 있었던 때

혼인무효의 소 : 당사자, 법정대리인 또는 4촌 이내 친족이 언제든지 제기할 수 있음

1. 혼인무효판결이 확정되면, 당사자 사이에 처음부터 혼인이 없었던 것이 됨.
2. 혼인에 기한 상속 등 권리변동은 무효. 출생한 자녀는 혼인 외의 자가 됨.
3. 혼인의 무효로 된 경우 당사자 일방은 과실 있는 상대방에 대하여 이로 인한 손해배상(정신적 포함)을 청구할 수 있음.

혼인의 취소

취소원인 : 혼인적령의 미달, 부모 등의 동의를 결여한 혼인, 근친혼, 중혼, 악질, 기타 중대한 사유가 있는 혼인, 사기 또는 강박에 의한 혼인

1. 취소원인이 있는 혼인도 법원의 판결에 의하여 취소될 때까지는 유효
2. 혼인취소의 효력은 **취소판결이 확정된 때에 발생하며, 소급하지 않음**
>> 혼인에서 출생한 자녀는 혼인 중의 자로 됨.
3. 혼인관계 및 인척관계의 종료
4. 당사자 일방은 과실 있는 상대방에 대하여 이로 인한 손해배상(정신적 손해배상 포함)을 청구할 수 있음.

혼인의 효과

일반적 효과

- 친족관계의 발생
- 부부의 성 : 각자 본래의 성을 그대로 유지
- 동거 · 부양 · 협조의 의무
- 성년의제 : 미성년자가 혼인(법률혼)을 한 때에 성년자로 봄

재산적 효과

• 법정재산제

✓ **부부별산제** : 부부의 일방이 혼인 전부터 가진 **고유재산**과 혼인 중 자기의 명의로 취득한 재산은 **특유재산**
(부부가 각자 관리·사용·수익)

✓ 혼인생활비용의 공동부담

✓ **일상가사**대리권과 일상가사채무의 연대책임

→ 부부의 공동생활에 필요로 하는 통상의 사무

• **부부재산계약** : 혼인이 **성립하기 전에** 그 재산에 대하여 자유롭게 계약
(혼인 성립 후에 부부가 체결한 것이 아님)

이혼

혼인해소의 원인

사망에 의한 해소 : 부부 일방의 사망, 실종신고, 인정사망

이혼에 의한 해소 : 협의이혼과 재판상 이혼

협의이혼

- 당사자의 이혼 합의
- 이혼신고 : '가족관계의 등록 등에 관한 법률'에 정한 바에 의하여 신고하여야 함
→ **협의이혼의 성립요건**
- 협의이혼을 하려는 자는
 - ① 가정법원의 확인
 - ② 일정 기간 경과(이혼숙려기간)
 - ③ 3개월 내 신고

재판상 이혼

- 이혼원인
 - ① 배우자의 부정(不貞)한 행위
 - ② 악의(惡意)의 유기(遺棄)
 - ③ 배우자 또는 그의 직계존속에 의한 심히 부당한 대우
 - ④ 자기의 직계존속에 대한 배우자의 심히 부당한 대우
 - ⑤ 3년 이상의 행방불명
 - ⑥ 기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유
- **조정**에 의한 이혼 : 조정전치주의의 적용
- **재판**에 의한 이혼 : 조정신청을 한 때에 소가 제기된 것으로 보며, 판결이 확정되면 이혼신고가 없더라도 혼인 해소

일반적 효과

혼인에 대하여 생긴 모든 효과가 소멸

자녀에 대한 효과

자녀의 신분 : 혼인 중의 출생자 지위 유지

양육문제 : 부모에 협의에 의하여 정함. 협의를 못하면 가정법원의 직권 또는 당사자의 청구로 결정

친권자의 결정 : 부모에 협의에 의하여 정함. 협의를 못하면 가정법원의 직권 또는 당사자의 청구로 결정

면접교섭권 : 친권자나 양육자가 아니어서 미성년의 자녀를 보호·양육하지 않는 부 또는 모와 그 자녀가 상호 간에 직접 만나거나 전화·편지 등을 통하여 접촉할 수 있는 권리

재산분할청구권 : 혼인관계의 파탄에 책임이 있는 배우자도 인정

손해배상청구권 : 과실 있는 상대방에 대한 재산상의 손해배상청구권과 위자료청구권 발생

친자관계

: 부모와 자녀의 신분관계

친생 친자관계 : 부모와 자녀의 관계가 혈연에 기초

-> 친생자 : 혼인 중의 출생자, 혼인 외의 출생자

법정 친자관계 : 부모와 자녀의 관계가 법률에 의한 것

-> 양친자관계 : 양자, 친양자 ----->

구분	양자	친양자
성립	협의	가정법원의 입양재판
자녀의 성과 본	친생부의 성과 본 유지 (자녀의 복리를 위하여 필요한 경우 변경 가능)	양부의 성과 본으로 변경
친생부모와의 관계	유지	종료, 단절
특징	✓ 입양된 때(입양신고일)부터 양부모의 혼인 중의 출생자 지위를 가짐 ✓ 친생부모 및 그 혈족, 인척 사이의 친족관계 존속	✓ 재판확정 시부터 혼인 중의 출생자로 간주 ✓ 입양 전의 친족관계의 종료

구분		유형과 특징	
친생자	혼인 중의 출생자	생래적 혼인 중의 출생자	법률혼 사이에서 태어난 출생자
		준정에 의한 혼인 중의 출생자	혼인 외의 출생자로 출생하였으나 부모가 혼인한 경우
	혼인 외의 출생자	✓부모가 혼인하지 않은 상태에서 출생 ✓모(母)와의 사이에서는 출산과 동시에 친자관계가 발생하나, 생부(生父)와의 사이에는 인지가 있어야 친자관계 발생	
양자		입양된 때(입양신고일)부터 양부모의 혼인 중의 출생자의 지위를 가짐	

후견

제한능력자나 그 밖에 보호가 필요한 사람을 보호하는 것. 법정후견 + 임의후견

법정후견

미성년후견 : 친권자가 없는 미성년자 또는 친권자가 법률행위의 대리권 및 재산관리권을 행사할 수 없는 경우
 >>친권자의 유언, 가정법원의 직권 또는 미성년자·친족·이해관계인·검사·지자체장의 청구에 의해 미성년후견인을 선임.

성년후견 : 판단능력이 지속적으로 전혀 없는 성인. 가정법원의 성년후견개시 심판이 있는 경우. 가정법원 직권.

한정후견 : 판단능력이 일시·부분적으로 없는 성인. 가정법원의 성년후견개시 심판이 있는 경우. 가정법원 직권.

특정후견 : 현재는 판단능력이 괜찮지만, 특정한 사안에 대해서만 일시적으로 보호가 필요한 경우. 필수X

임의후견

후견계약에 의한 후견 : 질병·장애·노병·그 밖의 사유로 사무를 처리할 능력이 부족한 상황에 있거나 이를 대비하여 사무를 다른 자에게 위탁하고, 위탁사무에 관하여 대리권을 수여하는 것.

상속

: 사람이 사망한 경우에 그의 재산상의 지위가 법률규정에 의하여 법률규정에 의하여 타인에게 포괄적으로 승계되는 것.

피상속인 : 사망하여 그의 재산상의 지위가 승계당하는 자(사망자)

상속인 : 피상속인의 재산상의 지위를 승계하는 자

유형

법정상속 : 상속인이 될 자의 범위와 순위가 법률상 정해져 있는 상속

유언상속 : 피상속인의 유언에 의하여 지정되는 상속.

민법은 법정상속만 규정. 민법상 유언의 자유가 인정되기 때문에 법정상속에 관한 규정은 유언이 없거나 무효인 경우에 보충적으로 적용.

상속의 개시

: 상속에 의한 법률효과가 발생하는 것

상속개시의 원인 : 피상속인의 사망(자연적 사망 + 법원의 실종선고에 의한 의제사망 + 인정사망)

상속개시의 시기 : 누가 상속인인가? - 피상속인의 사망 당시 살아있는 사람

상속은 피상속인의 사망과 동시에 법적 효력이 발생.

상속재산, 상속분, 유류분도 사망 당시를 기점으로 평가

상속개시의 장소 : 피상속인의 주소지

상속에 관한 비용 : 상속에 의하여 생긴 비용. 상속재산의 관리비용, 경매비용, 소송비용, 조세, 장례 등 포함
 상속비용은 상속재산 중에서 지급.

상속인

상속인의 자격

상속능력 : 상속인이 될 수 있는 능력(지위·자격)

권리능력이 있어야 하며, 피상속인의 **일정한 친족**에 한정. **자연인만** 가능

상속결격 : 상속에 적합하지 않은 일정한 사유가 있는 경우 상속인으로서의 자격을 상실하게 하는 것

상속인의 순위

혈족상속인

- ① 제1순위 : 피상속인의 **직계비속**
- ② 제2순위 : 피상속인의 **직계존속**
- ③ 제3순위 : 피상속인의 **형제자매**
- ④ 제4순위 : 피상속인의 **4촌 이내의 방계혈족**
- ✓ 동순위의 상속인이 수인인 때에는 **최근친을 선순위**로 하고
동친 등의 상속인이 수인인 때에는 **공동상속인**이 됨

배우자상속인

- 피상속인의 배우자는 피상속인의 직계비속이나 직계존속이 있는 경우에는 그 상속인과 동순위로 공동상속인이 되고, 그 상속인이 없는 때에는 단독상속인이 됨
- 혼인신고를 한 법률상의 배우자만 해당하고, 사실혼의 배우자는 포함되지 않음

대습상속 : 상속이 개시되기 전에 상속인이 될 피상속인의 직계비속 또는 형제자매가 사망하거나 결격된 경우, 그의 직계비속과 배우자가 사망 또는 결격된 자의 순위에 갈음(대신)하여 상속하는 것

상속의 효력

상속재산의 포괄승계의 원칙

피상속인의 재산에 관한 **모든 권리·의무**를 포괄적으로 승계

적극재산(권리)뿐만 아니라 **소극재산(채무)**도 포함되고, 아직 구체화되지 않은 재산법적인 법률관계 포함
승계 시기 : 상속이개시된 당시(피상속인의 사망 당시)

제사용 재산의 특별승계 - 묘지 등...

상속분 : 각 공동상속인이 상속재산에 대하여 가지는 권리·의무의 비율

법정상속분 : 혈족, 배우자에 따라서 비율이 다르게 책정되어 있음.

기여분 : 특별히 기여한 사람에게 더 줌

상속 승인과 포기

민법은 상속에 의한 권리·의무의 당연승계를 인정하면서, 한편 이를 **승인**하거나 **포기**할 수 있도록 규정
상속인에게 채무가 적극재산보다 많은 경우 불이익을 부담하지 않게 하기 위함.

상속의 승인

단순승인 : 권리·의무의 승계에 대한 전면적 승인

한정승인 : 피상속인의 채무를 상속재산의 한도 내에서 변제하겠다는 조건 하 상속을 승인한 것

상속의 포기

상속을 전면적으로 거부하여 **처음부터 상속인이 아니었던 효과**를 하는 상속인의 단독행위(일방)

상속의 승인·포기의 고려 기간

상속개시가 있음을 안 날부터 **3개월** 내에 단순승인, 한정승인 또는 포기를 할 수 있음.

상속인의 부존재

상속인이 존재하는지 여부가 불분명한 것.

상속재산의 관리, 상속재산의 청산·공고, 상속인의 수색·공고

특별연고자에 대한 재산분여

: 피상속인과 생활을 같이하고 있던 자, 피상속인의 요양 간호를 한 자, 기타 상속인과 특별한 연고가 있던 자

재산분여의 청구 : 상속인의 수색공고로 정해진 기간이 만료된 후 2개월 이내에 가정법원에 청구

>그래도 안나타나면 상속재산은 국가귀속됨.

유언

: 사람이 그의 사망 후의 법률관계 중 일정사항에 관하여 정하는 일방적인 의사표시

법적 성질

사인 행위 : 유언자의 사망으로 비로소 그 효력이 발생

상대방이 없는 **단독행위**. 일정한 방식에 따라서 해야 하는 **요식행위**.

유언자의 **독립한 의사**에 기한 것. 대리 허용X, 제한능력자여도 법정대리인의 동의를 필요 없음!

언제든지 **유언 철회** 가능

유언능력

17세 이상, 의사능력이 있으면 가능.

제한능력자는 법정대리인의 동의 없이 유언이 가능. but, 피성년후견인은 의사능력이 회복된 때만 가능.

방식

유언의 요식성 : 일정한 방식에 따라서 해야 함.

유언방식의 종류

- | | | | | |
|---------|-------|---------|---------|---------|
| 1. 자필증서 | 2. 녹음 | 3. 공정증서 | 4. 비밀증서 | 5. 구수증서 |
|---------|-------|---------|---------|---------|

유언철회

언제든지 철회할 수 있다.

유언자가 유언을 철회할 권리를 포기하지 못함.

임의철회 : 언제든지 유언 또는 생전행위로서 유언의 전부나 일부를 철회할 수 있음.

법정철회 : 전후의 유언이 저촉되거나 유언 후의 생전행위가 저촉되는 경우, 저촉된 부분은 철회한 것으로 봄.
유언자가 고의로 유언증서 또는 유증의 목적물을 파훼한 때에 그 파훼한 부분에 관한 유언은 철회한 것으로 봄.

추인(追認) : 추후에 인정. 나중에 인정해서 효력이 있는것으로 소급적용.

형법

형법 기본개념

형벌 : 과거에 대한 범죄. 고통을 내용으로

사형, 징역, 금고, 자격상실, 자격정지, 벌금, 구류, 과료, 몰수 등 9가지

보안처분 : 장래의 범죄를 예방. 반드시 고통을 내용으로 하지는 X

치료감호(치료소에 수용), 보호관찰, 보안관찰(경찰의 감독)

범죄의 예방적 기능

일반예방기능 : 형벌의 사전예고, 시행. 일반 국민의 범죄 예방

특별예방기능 : 범죄인 자신의 재범예방.

죄형법정주의

죄형법정주의 : 범죄와 형벌은 반드시 성문법에 의해 정해져야 함.

관습형법금지의 원칙.

명확성의 원칙 : 형사제재를 명확하게 해야 함. 절대적 부정기형 금지.

소급효금지 원칙 : 범죄와 그 처벌은 행위 당시 법률로 해야함

절차법에는 소급효 원칙 적용되지 않음

피고인에게 유리한 경우 소급효 허용

>> 그런데 특별법을 만들면 소급효가 가능할수도...?

판례에는 소급효금지원칙이 적용되지 않음.

유추해석금지 원칙

법조문의 문장과 표현대로 엄격히 해석(문리해석)해야 함.

피고인에게 유리한 유추해석은 허용. 불리한 것은 금지

적정성 원칙 : 정당하고 합리적이어야 함. 과잉금지원칙, 비례의 원칙.

형법의 효력

행위시법주의 : 행위 시의 법을 적용. 추급효. 구법주의

재판시법주의 : 재판 시의 법을 적용. 소급효 신법주의

우리나라는 행위시법주의.

★범죄가 계속되고 있던중 법률이 변경되면 신법을 적용★

구vs신법이 다르면 피고인이 유리한 쪽으로 해석.

속지주의 : 자기 나라 내에서 발생한 범죄. 자기나라 형법 적용. 외국인 포함

속인주의 : 자국민의 범죄행위를 어디서든 처벌.

보호주의 : 외국인이 외국에서 죄를 범했더라도 우리나라국민에 대한 범죄이면 우리나라 형법적용. 소말리아.

세계주의 : 외국인이 외국에서 외국사람에게 범죄를 저질른 경우라도 국제적 영향력이 크면 우리나라 형법 적용.

범죄란?

: 구성요건에 해당하고(구성요건해당성) + 위법하고(위법성) + 유책한(책임) 행위

구성요건해당성 : 구체적인 행위가 법률에 규정된 범죄의 구성요건에 합치하는 것

위법성 : 구성요건에 해당하는 행위가 법질서 전체의 입장에서 허용되지 않는다는 부정적인 가치판단.

책임 : 위법행위를 한 행위자에 대한 비난가능성

범죄의 종류

객관적 처벌조건 : 형벌권을 발생시키는데 필요한 외부적·객관적 사유

주관적 처벌조건 : 범죄가 성립한 경우 국가형벌권이 발동되기 위한 인적조건. 친족관계는 인적 처벌조각사유

범죄의 소추조건

친고죄 : 고소권자의 **고소가 있어야만** 공소제기를 할 수 있는 범죄 정지조건부 범죄

ex) 사자명예훼손죄, 모욕죄, 비밀침해죄, 업무상비밀누설죄

반의사불벌죄 : 고소가 없어도 공소제기가 가능하나, **피해자가 처벌을 원하지 않는다는** 의사를 명백히 한 경우에는 소추가 불가능한 범죄 해제조건부 범죄

ex) 폭행죄, 과실치상죄, 협박죄, 명예훼손죄, 출판물에 의한 명예훼손죄

범죄의 종류

결과범 : 일정한 결과 발생으로 인한 범죄

살인죄 절도죄 강도죄

거동범 : 구성요건에 규정된 행위를 함으로써 충족되는 범죄

폭행죄, 주거침입죄, 무고죄, 위증죄 등

침해범 : 현실적인 침해가 있어야 하는 범죄

살인죄 상해죄 절도죄

위험범 : 위험상태의 야기만으로 충족되는 범죄

즉시범 : 결과발생과 동시에 범죄가 기수에 이르고 종료

살인죄, 상해죄, 방화죄, 모욕죄

상태범 : 즉시범이지만, 기수 이후에도 위법상태가 계속되는 범죄.

불가벌적 사후행위 : 어떤 불법 이후에 지은 죄는 따로 추가하지 않음

계속범 : 법익침해상태가 어느 정도 시간적 계속이 있어야 성립. 체포,감금죄 주거침입죄 약취,유인죄

일반범 : 누구나 주체가 될 수 있음

신분범 : 일정한 신분을 요함

진정신분범 - 직원 등

부진정신분범 - 존속살해, 영아살해 등 가중

자수범 : 주체가 직접 범죄. 타인을 통해서 할 수 없는 죄

위증죄, 도주죄

구성요건해당성론, 위법성론, 책임론

구성요건해당성론 : 어떠한 구체적인 행위가 규정된 구성요건의 전부 또는 일부를 실현하는 성질

구성요건 : 형법상 금지 또는 요구되는 행위가 뭘지 기술해놓은 것.

인과관계 : 결과의 발생을 필요로 함. 결과범에서만 논의.

고의 : 객관적 상황을 인식하고, 구성요건을 실현하려는 의사.

확정적 고의 : 결과가 반드시 일어날 것을 알고도 일부러 그렇게 한 경우입니다.

불확정 고의 : 구 결과가 일어날 수도 있다는 걸 알면서도 그렇게 한 경우입니다.

미필적 고의 : 결과가 일어날 가능성이 있음을 알았지만, 그래도 괜찮다고 생각하고 한 경우입니다.

택일적 고의 : 여러 결과 중 어떤 것이든 생겨도 상관없다는 태도로 한 경우입니다.

과실 : 요구되는 주의의무를 위반 또는 태만한 경우.

1. 결과의 발생 + 2. 주의의무위반 + 주의의무위반과 결과 사이에 인과관계가 인정

고의범 : 행위자가 실제로 인식하고 의욕·인용한 사실이 중요

과실범 : 행위자에게 주의의무위반이 있었는가 하는 규범적 평가가 중요

>> 과실범은 의사가 아니고 **부주의**에 의한 것이므로 약하게 처벌

인식없는 과실 : 주의의무를 다하지 않아 구성요건의 실현가능성을 인식하지 못한 경우

인식있는 과실 : 실현가능성 인식했지만, 구성요건이 실행되지 않을 것으로 생각하고 결과발생을 피하지 않은 경우

경과실 : 중과실이 아닌 과실

중과실 : 주의의무를 현저히 태만한 경우.

업무상 과실 : 업무수행상 요구되는 주의의무를 태만한 경우. 보통과실에 비해서 중하게 처벌

부작위범 : 해야 할 행위를 하지 않음으로써 성립하는 범죄.

진정부작위범 : 구성요건이 부작위로 구성된 범죄. 퇴거 불응죄, 다중 불해산죄...

부진정부작위범 : 구성요건은 작위범의 형태, 아기를 돌볼 부모가 고의·과실로 돌봐주지 않음

위법성론

: 그 행위에 대해 부정적으로 평가하고 그 행위를 허용하지 않는다는 것을 의미

위법성조각사유 : 구성요건에 해당하는 행위의 위법성을 배제하는 특별한 사유

정당행위 : 법령, 업무로 인한 행위 기타 사회상규에 위배되지 아니하는 행위는 별하지 않음

정당방위 : 현재의 부당한 침해를 방위하기 위한 행위 + 상당한 이유

긴급피난 : 현재의 위난을 피하기 위한 행위 + 상당한 이유

자구행위 : 청구권의 실행불능 또는 실행곤란을 피하기 위한 행위

피해자의 승낙 : 처분할 수 있는 자의 승낙에 의하여 처벌하지 않음. 개인적 법익에만 한함.

책임론

: 행위자에게 가해지는 비난가능성

위법성 : “행위”에 대한 비난가능성

책임 : “행위자”에 대한 비난가능성

1. 책임능력이 있어야 함
2. 위법성을 인식하거나 인식할 가능성이 있어야 함
3. 적법행위에 대한 기대가능성이 있어야 함.

책임능력 : 범죄능력을 의미함. 책임능력이 요구되는 시험은 **범죄행위 시**

책임무능력자

형사미성년자 : 책임이 조각됨. 형벌을 과할 수 없음

심신상실자 : 심신장애. 책임능력이 없기 때문에 책임이 조각

한정책임능력자 : **책임능력자임**. NOT 책임무능력자

심신미약자 : 심신미약인 자. 형을 감경

농아자 : 청각과 발음기능 모두 장애가 있는자 형을 감경.

기대가능성 : 적법행위를 할 것을 기대할 수 있는 가능성

행위자에게 특수사정이 있는 경우 책임비난을 가할 수 없음 => 강요된 행위

위법성의 인식 : 법적으로 금지되어 있다는 것을 아는 것

법률의 착오 : 위법성의 인식 없이 위법한 행위를 하는 경우

직접적 착오 : 금지규범 자체를 인식하지 못하여 허용된다고 유인

간접적 착오 : 금지된 것은 인식하였으나 자기의 경우에는 위법성조각사유가 적용되어 허용된다고 오인한 경우.

미수론, 공범론

범죄실현의 단계

1. 범죄의 결심, 범죄의사의 표시 : 외부적 행위로 나타나야 함.
2. 예비, 음모 : **예비** - 범죄 준비행위 **음모** - 2인 이상 범죄의사를 교환하고 합의하는 것
3. 실행의 착수 : 실행의 개시. 실행의 착수가 있으면 종료나 결과발생과 상관없이 **미수단계에 이름**
4. 미수 또는 기수 **미수** - 종료X or 종료했지만 결과발생X **기수** : 종료 or 결과발생

5. 범죄의 종료 : 기수 이후 보호법의 대한 침해가 끝난 경우

장애미수 : 비자의적으로 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 않은 형태의 미수.

장애에 의한 범죄의 미완성. 기수범의 고의와 동일

>>미수범의 형은 기수범보다 감경할 수 있음.

중지미수 : 자의적으로 실행행위를 중지, 결과발생을 방지한 미수

>>필요적으로 감면

불능기수 : 실행하였으나, 실행의 수단 또는 대상의 착오로 처음부터 결과발생이 불가능한 미수.

>>감면할 수 있음.

단독범 : 1인

공범 : 수인이 하나의 범죄에 관계

임의적 공범 : 단독으로 할 수 있는 범죄에 수인이 관여하는 형태

필요적 공범 : 개념상 단독으로는 범할 수 없고 수인이 함께해야 범할수 있는 범죄 내란죄...

공동정범 : 2인 이상의 자가 공동의 계획범죄. 각자 분담을 이행. 분업의 원리

>> 각자를 그 죄의 정범으로 처벌

교사범 : 타인을 교사(사주)하여 범죄.

>>교사자를 피교사자와 동일한 형으로 처벌

종범 : 타인의 실행행위를 도와줌. 방조함.

>> 종범의 형은 정범보다 감경함.

죄수론

죄수론 : 범죄의 수를 정하는 문제

공범론 : 범인의 수

죄수론 : 범죄의 수.

일죄 : 범죄의 수가 1개

수죄 : 수 개의 행위로 수 개의 죄를 범함. 경합범.

형벌론

형벌 : 국가가 범죄에 대한 법률상의 효과로서 범죄자에 대하여 과하는 법익의 박탈

형벌(과거) vs 보안처분(미래)

생명형 : 생명을 박탈. 사형. 교수하여 집행

자유형 : 신체의 자유 박탈.

징역 : 정역에 복무

금고 : 정역을 부과하지 않음

구류 : 1~30일내 구치

재산형 : 일정한 금액의 지급의무 강제부다

벌금 : 5만원 이상. 미납시 노역장에 유치

과료 : 2천원~5만원 미만. 경미한 범죄에. 미납시 노역장에 유치

몰수 : 범죄행위와 관련된 재산을 박탈하여 국고귀속. 몰수할 수 없는 경우 가액 추징

명예형 : 명예 또는 자격박탈(공무담임권, 선거/피선거권, 공법상의 업무자격, 법인의 이사/감사/지배인이 될 자격)

자격상실 : 사형.무기징역.무기금고의 선고가 있으면 일정 자격이 당연히 상실

자격정지 : 일정 기간 동안 일정 자격의 전부 또는 일부 정지

집행유예 : 유죄 인정. 형의 집행 유예. 유예기간 경과하면 선고효력 상실.

3년이하 징역, 500만원이하 벌금. 보호관찰, 사회봉사, 수강 명할 수 있음
1~5년 내에 법원의 재량으로 선고. 경과되면 형의 선고효력 없음
> 전과자가 되지 않음!
금고이상 형 선고받고 확정되면 효력을 잃음

선고유예 : 경미한 범죄인에 대하여 형의 선고를 유예하고, 사고없이 경과하면 면소된 것으로 간주
1년이하 징역,금고... 개선의 여지가 있을 때
전과가 없을 때.
선고유예는 무조건 2년

가석방 : 개선의 정이 현저하면 조건부로 석방. 일정한 기간을 경과하면 형의 집행을 종료한것으로 간주
무기 - 20년 이상 유기 - 1/3 경과
개전의 정 현저.
무기징역은 10년, 유기형은 남은 형기

형법총칙 vs 형법각칙

형법총칙 : 개별 범죄들에게 공통적으로 성립하는 범죄성립요소와 그 효과인 형벌·보안처분 등과 같은 형사제재

형법각칙 : 개별 범죄유형 그 자체를 기술. 다른 범죄유형과 구분이 되도록 기준을 제시

형법각칙

국가적 법익에 대한 죄 : 국가의 존립과 권익 또는 그 기능을 보호하기 위한 범죄

사회적 법익에 대한 죄 : 공동생활의 기초가 되는 사회생활에서의 일반적 법익을 보호하기 위한 범죄

개인적 법익에 대한 죄 : 개인적 인격적 가치와 재산적 가치를 보호하기 위한 범죄

개인적 법익에 대한 죄

생명과 신체에 대한 죄

살인(~의 죄): 고의로 사람을 살해함

상해와 폭행 : 상해(신체의 건강. 침해범) vs 폭행(신체의 건강. 형식범)

과실치사상 : 과실로 인하여 사람을 사망에 이르게 하거나 상해하는 것.

낙태 : 인위적으로 모체 밖으로 태아를 배출하거나 살해하는 범죄.

자유에 대한 죄

체포와 감금 : 불법하게 체포 또는 감금함으로써 신체적 활동의 자유를 침해하는 범죄.(침해범)

협박 : 개인의 의사결정의 자유를 침해함.

약취와 유인 및 인신매매 : 개인의 자유로는 생활관계를 침해하는 것.

강간과 추행 : 개인의 성적 자기결정권의 자유. **친고죄가 아님!** 침해범.

강요 : 폭행 또는 협박. 권리행사를 방해하거나 의무 없는일을 하게 함. 침해범.

명예와 신용에 대한 죄

명예 : 공연히 사실을 적시하여 사람을 모욕. 사실을 적시하여도 명예훼손죄가 될 수 있음. 추상적 위험범.

명예훼손죄 : 구체적 사실의 적시

모욕죄 : 단순한 추상적 판단이나 경멸적 감정의 표현

신용·업무와 경매 : 신용을 훼손하거나 업무를 방해하거나 경매·입찰의 공정성을 침해하는 것을 내용으로 하는 범죄

사생활의 평온에 대한 죄

비밀침해 : 개인의 사생활에 있어서 비밀을 침해하는 내용. **친고죄**

비밀침해죄 : 개인의 비밀.

업무상비밀누설죄 : 개인의 비밀 + 특정직업종사자들의 비밀준수에 대한 신뢰.

주거침입 : 주거 또는 관리하는 장소의 평온과 안전을 침해하는 것.

재산에 대한 죄

절도 : 타인의 재물을 절취하는 것. 타인의 점유배제와 새로운 점유취득을 내용으로 함.

강도 : 폭행 또는 협박으로 타인의 재물을 강취, 재산상의 이익 취득

사기 : 사람을 기망하여 재물을 편취, 재산상의 불법한 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 얻게 하는 행위

공갈 : 공갈하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득. 공갈==폭행 또는 협박으로 공포심.

횡령 : 자기가 보관하는 타인의 재물이나 점유이탈물을 불법하게 영득.

배임 : 타인의 업무를 처리하는 자가 배임행위(임무위배행위)에 재산상의 이득, 본인에게 손해를 가하는 것

장물 : 장물을 취득.양도.운반.보관.알선

손괴 : 타인의 재물, 문서 또는 전자기록 등 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 그 효용을 해하는 것

권리행사 방해 : 자기의 물건에 대한 타인의 권리행사를 방해, 강제집행을 면할 목적으로 채권자를 해하는 것

권리행사 방해죄 : 제한물권과 채권

점유강취죄 : 제한물권

강제집행면탈죄 : 강제집행권이 발동될 단계에 있는 채권자의 채권

사회적 법익에 대한 죄

공공의 안전과 평온에 대한 죄

공안을 해하는 죄 : 공공의 안전을 평온을 해함.

폭발물에 관한 죄 : 폭발물을 사용

방화와 실화의 죄 : 고의 또는 과실로 불을 놓아 건조물 등을 소훼.

일수와 수리에 관한 죄 : 고의 또는 과실로 수해를 일으켜 공공의 안전을 해하는 것

교통방해의 죄 : 공공의 교통설비를 손괴 또는 불통하게 함. 교통을 방해

공공의 신용에 대한 죄

통화에 관한 죄 : 통화를 위조, 변조 등등.

유가증권·인지와 우표에 관한 죄 : 유가증권을 위조, 변조, 허위작성.

문서에 관한 죄 : 문서를 위조,변조하거나 그 문서를 행사하거나 부정행사하는 것

인장에 관한 죄 : 인장·서명·기명·기호를 위조 또는 부정사용하거나 이를 행사.

공중의 건강에 대한 죄

음용수에 관한 죄 : 사람의 음용에 사용하는 정수 또는 수원에 공중의 음용수이용과 안전을 위태롭게 하는 것.

아편에 관한 죄 : 아편을 흡식하거나 아편 또는 아편흡시도구를 제조·수입·판매 또는 소지하는 것.

사회의 도덕에 대한 죄

성풍속에 관한 죄 : 성도덕 내지 성풍속을 해하는 행위 음행매개죄, 음란물죄·공연음란죄

도박과 복표에 관한 죄 : 도박하거나 도박장소를 개장, 복표를 발매·중개 또는 취득하는 것

신앙에 관한 죄 : 공중의 종교생활의 평온과 종교감정을 침해하는 것을 내용으로 하는 범죄

국가적 법익에 대한 죄

국가의 존립과 권위에 대한 죄

내란의 죄 : 국가의 내부로부터 헌법의 기본질서를 침해하여 국가의 존립을 위태롭게 하는 것을 내용. 공범 必

외환의 죄 : 외환을 유치하거나 대한민국에 항적하거나 적국에 이익을 제공

국기에 관한 죄 : 국기 또는 국장을 손상·제거·오욕·비방을 하는 것을 내용으로 하는 범죄

국교에 관한 죄 : 국제법상 보호되는 외국의 이익을 침해함으로써 외국과의 국교관계를 해하는 것

국가의 기능에 관한 죄

공무원의 직무에 관한 죄 : 공무원이 직무를 위배, 직권 남용, 뇌물 수수

공무방해에 관한 죄 : 공권력 행사를 방해하는 것을 내용으로 함

도주와 범인은닉의 죄 : 도주 - 체포·구금된 자가 도주하거나 타인이 범인의 도주에 관여하는 것.

범인은닉 - 벌금 이상의 형에 해당하는 죄를 범한 자를 은닉·도피하게 하는 것

위증과 증거인멸의 죄 : 위증 : 법률에 의하여 선서한 증인이 허위의 진술을 하는 것

증거인멸의 죄 : 타인의 증거를 위조, 변조·삭제·증인을 은닉·도피하게 함

무고의 죄 : 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 허위의 사실을 신고함

형사소송법

: 형사절차를 규정하는 국가적 법률체계. 형법을 적용·실현하기 위한 절차

형사소송법의 적용 없이는 형법을 구체적으로 실현할 수 없음.

형사절차법정주의 : 형사절차가 단순히 법률에 규정되어 있을 것 + 법률에 규정된 형사절차가 적정한 절차일 것

성격 : 공법, 사법법(재판에 관한 법), 형사법, 절차법

실체진실주의 : 소송의 실체에 관하여 객관적 진실을 발견하여 사안의 진상을 명백히 하자는 주의

수사절차 : 임의수사와 불구속수사 원칙. 강제수사는 엄격한 법정절차에 의해서만 적용

공소제기단계 : 검사의 공소사실 특정의무, 법원의 공소장변경요구

공판절차 : 법원의 피고인신문, 증인신문·직권증거조사, 증거재판주의, 자유심증주의, 위법수집증거배제법칙, 자백배제법칙, 전문법칙, 자백의 보강법칙

상소와 재심제도

적정절차의 원리

공정한 재판의 원칙 : 공평한 법원의 구성, 피고인의 방어권 보장, 무기평등의 원칙

비례성의 원칙 : 방법의 적절성, 침해의 최소성, 혐의의 비례원칙

피고인보호의 원칙 : 피고인의 방어능력 유지

신속한 재판의 원칙

수사와 공소제기의 신속

공판절차의 신속한진행

상소심재판의 신속

특수한 공판절차 - 간이공판절차, 약식절차, 즉결심판절차

규문주의와 탄핵주의

규문주의 : 법원이 스스로 절차를 개시하여 심리·재판. 재판의 권한이 법관에게

탄핵주의 : 재판과 소추기관 분리. 법원은 공소제기된 사건만 심판할 수 있음. 불고분리의 원칙

당사자주의와 직권주의

당사자주의 : 검사와 피고에게 주도적 지위 인정. 법원은 제3자의 입장에서 당사자의 주장과 입증을 판단.

직권주의 : 형사소송의 주도적 지위를 검사나 피고인에게 맡기지 않고 법원에 인정

>> 당사자주의를 근간으로 하고, 보충적으로 직권주의

형사소송의 주체, 변호인

소송주체 : 소송법적 법률관계의 주체. 법원(재판권의 주체) + 검사(공소권의 주체) + 피고인(방어권의 주체)

당사자 : 검사 + 피고인

소송관계인 : 변호인, 보조인, 법정대리인, 대표자, 특별대리인, 고소인, 고발인, 증인, 감정인... 변호인은 보조자!

소송의 주체

법원 : 법률상 다툼에 관하여 심리를 행사하는 국가기관

★중요★

제척 : 법률에 **유형적으로** 설정해 놓고, 그 사유에 해당하는 법관을 직무집행에서 **자동적으로** 배제

기피 : 당사자의 신청에 의하여 직무집행에서 탈퇴.

당사자 신청 > 법원의 결정

회피 : 법관이 스스로 직무집행에서 물러남.

법관의 신청 > 법원의 결정

관할 : 특정법원이 특정사건을 재판할 수 있는 권한

검사 : 검찰권을 행사하는 국가기관

수사절차 : 특정 사건에 대해서만 수사의 주재자. 일반사법경찰과의 상호협력

수사의 결과 : **공소제기여부를 독점적으로** 결정

공판절차 : 피고인에 대립되는 당사자. 법원에 대하여 법령의 정당한 적용을 청구

재판 확정 시 : 형의 집행을 지휘·감독

1. **준사법기관**으로서의 검사 : 피의자·피고인의 인권과 밀접한 관련.

2. **단독관청**으로서의 검사 : 검찰사무를 처리하는 단독제의 관청. 자기의 이름으로 사건처리

조직의 특수성 : 검사의 권한행사에 대한 내부적인 통제 필요. 직무상의 독립성 보장.

법무부장관 - 일반적으로 검사를 지휘 감독, **검찰총장** - 구체적 사건에 대해 지휘·감독

검사의 지위 :

수사권(6대범죄) + 수사지휘권 + 수사종결권 + 사법통제권

공소제기의 독점자 + 공소수행의 담당자 + 당사자로서의 검사(피고인과 대립)

검사의 객관의무

재판의 집행지휘(한 법원에 대응한 검찰청 검사가 지휘) + 형집행을 위한 소환과 구인

피고인 : 형사소추를 당한 자.

피의자 : 공소제기 전에 수사기관에 의하여 수사의 대상으로 되어 있는자

수형자 : 확정판결에 의하여 형의 집행을 받고 있는 자

피고인은 **공소장에** **특정**되어야 함.

피고인의 지위 : 소송당사자(방어권의 주체) + 증거방법으로서의 지위(인적; 임의진술 + 물적; 신체)

절차의 대상(소환·구속·압수·수색 등 강제처분의 객체)

변호인 : 피의자나 피고인의 보조자로서 소송관계인

사선변호인 : 피고인·피의자 또는 그와 일정한 관계가 있는자가 선임한 변호인

국선변호인 : 법원에 의하여 선임된 변호인.

직권에 의한 사유 + 청구에 의한 사유 + 필요에 의한 사유

수사

: 범죄의 혐의가 있다고 생각할 때 수사기관이 개시하는 **조사활동**

내사 : 아직 범죄혐의가 확인되지 않은 단계에서 단순히 혐의의 유무만을 조사

수사기관

검사 : 특정 사건에 대하여만 수사. 6대사건. 일반사법경찰과 상호협력

사법경찰관리 : 6대범죄 이외에는 직접 수사.

수사의 조건 : 범죄의 주관적 혐의 + 수사의 필요성(공소제기의 가능성) +수사의 상당성(신의칙+비례의 원칙)

수사의 단서 : 수사기관이 범죄혐의가 있다고 판단하게 되는 원인
자율적 개시(자체판단) + 타율적 개시(고소, 고발, 자수 등)

고소 : 고소권자

고발 : 고소권자 이외 누구든지

임의수사 : 강제력을 행사하지 아니하고 상대방의 동의·승낙을 받아서 하는 수사. 임의수사가 원칙

강제수사 : 인권을 제한. 영장주의 법칙, 강제수사법정주의(특별한 규정이 있어야만), 필요최소한도(비례의 원칙

체포 : 48시간 동안 수사관서 등 일정한 장소에 인치. 체포영장 청구권은 검사에게.

긴급체포 : 영장주의 예외. 중대성, 상당성, 필요성, 긴급성 고려

구속 : 체포에 비하여 장기간에 걸쳐 제한

범죄혐의의 상당성이 있을 것 + 구속사유가 있을 것(도망, 주거부정, 증거인멸우려 등) + 비례성의 원칙

피의자의 구속기간

사법경찰관의 구속 : 10일 이내 검사에게 인치하지 않으면 석방해야 함.

검사의 구속 : 10일 이내에 공소를 제기하지 않으면 석방. 다만 지법판사의 허가를 얻어 1회에 한하여 연장 가능

피고인의 구속기간

구속기간 2개월. 계속할 필요가 있으면 심급마다 2개월마다 갱신

체포·구속적부심사제도 : 불법한 체포·구속, 부당한 계속구금에 대하여 청구

수사의 종결 : by 검사. 공소의 제기(유죄판결을 받을 수 있다고 인정될 경우) OR 불기소처분

재정신청 : 고소인 or 고발인이 불기소에 불복. 고등법원이 판단.

검찰청법에 의한 항고, 재항고

공소의 제기

국가소추추의, 검사만 공소제기. 검사의 재량으로 불기소처분 가능. 기소변경주의(공소의 취소를 인정)

공소장에 피고인, 죄명, 공소사실, 적용법조를 기재하여야 함.

공소제기 -> 피의자에서 피고인으로 -> 주도권이 법원으로 -> 법원은 공소사실만 심판 -> 공소시효 정지

공소시효 : 검사가 일정기간 공소를 제기하지 않으면 국가의 소추권을 소멸시키는 제도

사형 25년...

기산점은 범죄행위가 종료한 때부터 진행

공소시효의 정지 : 공소의 제기, 범인의 외국도피, 재정신청, 소년보호사건의 심리개시결정

공소제기되지 않았거나 제기되었어도 확정판결이 나지 않으면 면소.

공판

: 공판정에서 행하는 심리와 재판

공개주의 : 심리과정과 재판결과를 일반인에게 공개함

구두변론주의 : 구두에 의한 변론을 근거로 함. 구두-구술로 변론-소송주체에게 지휘권 부여.

직접주의 : 공판기일에 직접적으로 심리·조사한 증거만을 실체판단의 기초로 삼을 수 있음.

집중심리주의 : 2일 연속 요하면 연일 계속해서 심리해야 한다.

불고분리의 원칙 : 법원은 공소를 제기한 피고인과 범죄사실에 대해서만 심판할 수 있음.

공소장 변경 : 동일성을 해하지 않는 범위 내에서 법원의 허가를 얻어 공소사실 또는 적용법조를 추가,철회,변경

공판준비절차 : 공판기일에서 심리를 준비하기 위하여 수소법원에 의하여 행해지는 절차

모두절차 : 진술거부권 고지, 인정신문, 검사 모두진술, 피고인 모두진술...

사실심리절차 : 증거조사(당사자+법원직권), 피고인신문, 최종변론

판결선고절차 : 판결선고기일 판결선고.

증거

: 사실관계의 확인을 위한 자료

증거방법 : 사실인정의 자료가 되는 **유형물 자체**

증거자료 : 증거방법을 조사함에 의하여 알게 된 내용

증거재판주의 : 엄격한 증명.

거증책임 : 무죄추정의 원칙 + 의심스러울 때에는 피고인의 이익이 원칙. 검사가 거증책임을 짐.

자유심증주의 : 증거의 증명력을 법관의 자유로운 판단에 맡김.

자백의 보강법칙 : 자백은 보강증거가 꼭 필요하다.

위법수집증거배제법칙 : 위법한 절차에 의하여 획득한 증거는 증거능력 부정

자백배제법칙 : 임의성이 의심되는 자백의 증거능력을 부정

전문증거 :

특별절차

약식절차 : 검사의 청구가 있을 때. 공판X 약식으로 피고인에게 벌금·과료·몰수하는 간이한 형사절차

즉결심판절차 : 지법, 지원 또는 시군 법원 판사가 경찰서장에 의해 청구한 경미한 범죄. 20만원 이하.

심리와 재판은 공개된 재판에서.